GRUPO: II – CLASSE VII – Plenário
TC nº 027.973/2007-2
NATUREZA: Representação
INTERESSADO: Tribunal de Contas da União
ÓRGÃO: Ministério dos Transportes
ENTIDADE CONTRATADA: Poliedro Informática, Consultoria e Serviços Ltda. (CNPJ nº 02.660.447/0001-12)
SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. AUDITORIA NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES COM O OBJETIVO DE AVALIAR A TERCEIRIZAÇÃO NO SETOR DE INFORMÁTICA. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM CONTRATO CUJO OBJETO FOI A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÕES.

1. No caso de empresas tributadas sobre o lucro real, obrigatoriamente enquadradas no regime não-cumulativo do PIS, o percentual reservado ao PIS nas planilhas de custo e formação de preços, conforme expressamente determina o artigo 2º da Lei nº 10.637/02, é de 1,65%. Em acréscimo, o artigo 30 da Lei nº 10.833/03 determina que os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de direito privado pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, dentre outros, estão sujeitos à retenção na fonte da contribuição para o PIS/PASEP com o percentual de 0,65%, de acordo com o disposto no artigo 31 da mesma Lei.

2. O artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01 majorou a contribuição vinculada ao FGTS devida pelos empregados em 0,5%. Todavia, o § 2º do mesmo diploma legal estabeleceu que a contribuição majorada seria devida por 60 (sessenta) meses, a contar de sua exigibilidade (1/1/2002), sendo extinta, por conseqüência, em 1/1/2007.

3. A repactuação de preços não foi editada pelo Decreto nº 2.271/97 como figura jurídica autônoma, mas como espécie de reajuste de preços, a qual, ao contrário de valer-se da aplicação de índices de preços, adota apenas a efetiva alteração dos custos contratuais. Desse modo, não há se falar em inconstitucionalidade quanto ao aspecto previsto no artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal.

4. Sendo a repactuação contratual um direito que decorre de lei (artigo 40, inciso XI, da Lei nº 8.666/93) e, tendo a lei vigência imediata, forçoso reconhecer que não se trata, aqui, de atribuição, ou não, de efeitos retroativos à repactuação de preços. A questão ora posta diz respeito à atribuição de eficácia imediata à lei, que concede ao contratado o direito de adequar os preços do contrato administrativo de serviços contínuos aos novos preços de mercado.

5. A partir da data em que passou a viger as majorações salariais da categoria profissional que deu ensejo à revisão, a contratada passou deter o direito à repactuação de preços. Todavia, ao firmar o termo aditivo de prorrogação contratual sem suscitar os novos valores pactuados no acordo coletivo, ratificando os preços até então acordados, a contratada deixou de exercer o seu direito à repactuação pretérita, dando azo à ocorrência de preclusão lógica.

Trata-se de Representação formulada por equipe de auditoria deste Tribunal em decorrência de fiscalização realizada no Ministério dos Transportes, com o objetivo de avaliar a terceirização no setor de informática desse Ministério (Fiscalis nº 568/2007).

2. Segundo a equipe de auditoria, o Contrato nº 20/2005, firmado entre a União, por intermédio da Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério dos Transportes (SAAD/MT), e a empresa Poliedro Informática, Consultoria e Serviços Ltda., e cujo objeto é a contratação de empresa especializada no ramo de informática para executar os serviços de manutenção de sistemas de informática no âmbito do Ministério, estaria eivado das seguintes irregularidades:

(i) pagamentos contendo percentuais indevidos (1,65%) a título de PIS, enquanto que, conforme informações nas notas fiscais, a empresa retém 0,65% relativo a esse tributo, e devido a não-cumulatividade prevista na legislação, cabe à empresa o ônus de provar que arca com percentual superior a esse;

(ii) pagamentos contendo percentuais indevidos a título de FGTS e rescisões sem justa causa, respectivamente em 8,5% e 4,25%, quando, a partir de 1º de janeiro de 2007, os percentuais desses encargos passaram a ser 8% e 4%;

(iii) faturamentos e pagamentos realizados em desacordo com as regras editalícias de medição (horas de serviços prestados), pois em diversas faturas foram consideradas 176 horas de serviços prestados, o que equivale a 22 dias úteis, sendo que há meses em que não se atingiu essa quantidade de horas; e

(iv) pagamento referente à repactuação do Contrato nº 20/2005 com efeitos financeiros retroativos a 1/5/2005, sem previsão legal que subsidie tal decisão, sendo que os efeitos financeiros da repactuação deveriam retroagir, no máximo, a 10/4/2007, data da solicitação da contratada.

3. Em instrução inicial, a Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti), propôs fosse realizada a audiência da Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério dos Transportes (SAAD/MT), bem como da empresa Poliedro Informática, Consultoria e Serviços Ltda., para que se pronunciassem a respeito dos indícios de irregularidades acima mencionados (fls. 1/10, v.p.).

4. Em 28/11/2007, a SAAD/MT encaminhou, por intermédio do Ofício nº 118/2007-SAAD/SE/MT (fl. 1, anexo 2), informações a respeito do andamento do atendimento à audiência, ocasião em que anexou a documentação de fls. 2/90, anexo 2, e informou que solicitara esclarecimentos à empresa Poliedro acerca dos indícios de irregularidades elencados.

5. Em 30/11/2007, a empresa Poliedro enviou a este Tribunal as suas razões de justificativa (fls. 91/160, anexo 2), ao passo que, em 5/12/2007, a SAAD/MT enviou o Ofício nº 121-2007/SAAD/SE/MT (fl. 161, anexo 2), ao qual anexou documento de igual teor àquele apresentado pela Poliedro.

6. A Consultoria Jurídica do Ministério dos Transportes, por sua vez, encaminhou os esclarecimentos insertos às fls. 237/268, anexo 2, v. 1.

7. Ao examinar o feito, a ACE lotada na Sefti elaborou a instrução de fls. 24/45, v.p., da qual transcrevo o trecho a seguir, *verbis*:

"(...)

I - Da irregularidade nas planilhas de custos e formação de preços

Ponto questionado*: percentuais indevidos (1,65%) a título de PIS, enquanto que, conforme informações nas notas fiscais, a empresa retém 0,65% relativo a essa contribuição, e, devido a não-cumulatividade prevista na legislação, cabe à empresa o ônus de provar que arca com percentual superior a esse.*

Razões de Justificativa dos responsáveis

8. Com relação à questão em tela, a Subsecretaria de Assuntos Administrativos, conforme Ofícios nos 121/2007/SAAD/SE/MT e 118/2007/SAAD/SE/MT, não se pronunciou, restringindo-se a promover a manifestação da contratada (fls. 161/162, anexo 2).

9. Os esclarecimentos expostos pela empresa alicerçam-se no fato de ela ser tributada no regime do lucro real e, por conseqüência, ser obrigatoriamente enquadrada no regime não-cumulativo do PIS, que impõe aplicação do percentual de 1,65% sobre a receita auferida. A contratada elucida que, para as pessoas jurídicas tributadas de acordo com esse regime, os percentuais incidentes nas retenções de tributos federais, efetuadas pelas fontes

pagadoras, não correspondem exatamente à carga tributária efetiva, que é calculada ao final do período-base (fls. 105/107, anexo 2).

10. Para respaldar esse entendimento, a contratada fez menção ao normativo que rege a retenção de tributos e contribuições, (art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e a Instrução Normativa SRF nº 480 de 15 de dezembro de 2004 e suas alterações).

11. Dessa forma, a Poliedro conclui que, por ser tributada sobre o lucro real, as retenções promovidas pelo Ministério dos Transportes nas faturas da empresa observam somente a retenção na fonte pagadora e não a realidade tributária a que está sujeita, sendo que a diferença questionada na Representação já seria objeto de recolhimento junto à Receita Federal no momento oportuno (fls.110/111, anexo 2).

Análise

12. A contribuição para o PIS segue as regras gerais de apuração (incidência não-cumulativa e incidência cumulativa), além de diversos regimes especiais. No regime de incidência cumulativa, a base de cálculo é o total das receitas da pessoa jurídica, sem deduções em relação a custos, despesas e encargos. Nesse regime, as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep é de 0,65%. As pessoas jurídicas de direito privado que apuram o IRPJ com base no lucro presumido ou arbitrado estão sujeitas à incidência cumulativa.

13. A retenção de 0,65%, referente ao PIS, feita nos pagamentos à empresa contratada, está de acordo com a Lei nº 9.430/1996, em especial seu art. 64, que define as regras para a retenção de tributos e contribuições, e com o disposto nos §§ 4º e 5º do art. 2º da IN/SRF nº 480/2004,.

14. Adicionalmente, a Lei nº 10.833/2003, nos artigos 30 e 31, estabelece que estão sujeitos a retenção na fonte da contribuição para o PIS os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços profissionais, mediante aplicação da alíquota de 0,65% sobre o montante a ser pago.

15. Entretanto, as pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base no lucro real estão sujeitas à incidência não-cumulativa, que permite o desconto de créditos apurados com base em custos, despesas e encargos da pessoa jurídica. Para esse regime, a Lei nº 10.637/2002, art. 2º, determina a aplicação da alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) para cálculo do valor da contribuição para o PIS.

16. Ante o esclarecimento da contratada acerca do regime ao qual se sujeita, sendo tributada com base no lucro real, resta comprovado o ônus da empresa quanto à alíquota de 1,65% referente à contribuição para o PIS e presente nas planilhas de custo do contrato em tela.

17. Considerando as justificativas apresentadas e os normativos relacionados, conclui-se que:

17.1. Devem ser acolhidas as razões de justificativas apresentadas pela empresa Poliedro;

17.2. Consideram-se regulares as alíquotas cobradas e retidas a título de PIS, restando elidido o citado indício de irregularidade declarado na Representação.

II - Da irregularidade nos pagamentos no decorrer do contrato

***Ponto questionado**: percentuais indevidos a título de FGTS e Rescisões sem justa causa, respectivamente em 8,5% e 4,25%, quando a partir de 1º de janeiro de 2007 os percentuais destes encargos passaram a ser 8% e 4%.*

Razões de Justificativa dos responsáveis

18. Por meio do Ofício nº 121/2007/SAAD/SE/MT (fls. 161, anexo 2), a Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério dos Transportes informa estar adotando as providências com vistas a obter as devoluções devidas. Essa decisão foi tomada em função dos esclarecimentos apresentados pela empresa contratada, em que ela reconhece a irregularidade dos percentuais cobrados a título de FGTS e Rescisões sem justa causa, e declara ser justa a reparação de tal situação, afirmando que não oferecerá óbice ao ressarcimento desses valores (fls. 100/101, anexo 2).

Análise

19. A Lei Complementar nº 110/2001, que entrou em vigor em 01/01/2002, elevou a contribuição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS de 8% para 8,5%. O § 2º do art. 2º dessa lei previa que o acréscimo de 0,5% na contribuição vigeria pelo prazo de 60 (sessenta) meses a contar de sua exigibilidade. Dessa forma, desde 01/01/2007 o percentual do FGTS voltou ao patamar de 8%.

LC nº 110/2001:

'Art. 2º Fica instituída contribuição social devida pelos empregadores, à alíquota de cinco décimos por cento sobre a remuneração devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas as parcelas de que trata o art. 15 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990. (Vide: ADIN 2.556-2 e ADIN 2.568-6)

(...)

§ 2º A contribuição será devida pelo prazo de sessenta meses, a contar de sua exigibilidade.

(...)

Art. 14. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos: (Vide: ADIN 2.556-2 e ADIN 2.568-6)

I – noventa dias a partir da data inicial de sua vigência, relativamente à contribuição social de que trata o art. 1º; e (Vide: ADIN 2.556-2 e ADIN 2.568-6)

II – a partir do primeiro dia do mês seguinte ao nonagésimo dia da data de início de sua vigência, no tocante à contribuição social de que trata o art. 2º. (Vide: ADIN 2.556-2 e ADIN 2.568-6)'

20. Inclui-se nessa norma legal a contribuição a título de FGTS Rescisões sem justa causa, que, com o término da vigência do dispositivo da Lei, deveria ter tido seu valor percentual, cobrado na planilha de custos e formação de preços, diminuído ao patamar de 4% desde 01/01/2007.

21. Todavia, como não houve alteração alguma nos valores contratuais nessa data, os pagamentos efetuados à empresa Poliedro continuam considerando os percentuais de 8,5% e 4,25%,conforme consta nas planilhas de formação de preços originais dos diversos profissionais que prestam os serviços ao Ministério dos Transportes (fls. 111/122, anexo 1).

22. Segundo cálculo estimativo, conforme memória de cálculo (Apêndice I, Memória de Cálculo), os valores devidos em razão dessa diferença de percentuais são da monta de R$ 11.292,12 (onze mil, duzentos e noventa e dois reais e doze centavos).

23. A despeito do propósito do Ministério dos Transportes de reaver os valores pagos a maior, manifestado no início do mês de dezembro de 2007, e da anuência da Poliedro quanto às devoluções devidas, até o dia 24 de janeiro de 2008, data em que foi realizada consulta ao Siafi, os valores referentes aos pagamentos indevidos a título de FGTS e Rescisões sem justa causa ainda não haviam sido glosados (fls. 276/294, anexo 2, v. 1).

24. Ante as considerações feitas, conclui-se que:

24.1. Consideram-se indevidos os pagamentos feitos pelo Ministério dos Transportes à empresa Poliedro a partir de 1º de janeiro de 2007 a título de FGTS e Rescisões sem justa causa, respectivamente em 8,5% e 4,25%, quando os percentuais destes encargos passaram a ser 8% e 4%;

24.2. O Ministério dos Transportes deve efetuar o cálculo e a glosa dos pagamentos efetuados a maior referentes às alíquotas de FGTS e Rescisão sem justa causa efetuados à empresa Poliedro;

24.3. O Ministério dos Transportes deve efetuar a revisão das alíquotas referentes ao FGTS previstas em todos seus contratos de prestação de serviços contínuos.

III - Dos indícios de superfaturamento

***Ponto questionado**: faturamentos e pagamentos realizados em desacordo com as regras editalícias de medição (horas de serviços prestados), pois em diversas faturas foram consideradas 176 horas de serviços prestados, o que equivale a 22 dias úteis, sendo que há meses em que não se atinge esta quantidade de horas, como por exemplo em maio de 2005 (21 dias úteis, equivalentes a 168 horas), fevereiro de 2006 (18 dias úteis, equivalentes a 146 horas) e fevereiro de 2007 (19 dias úteis, equivalentes a 152 horas).*

25. Inicialmente, quanto à questão, cumpre ressaltar que o ponto elucidado já foi tratado no âmbito do Contrato nº 20/2005, como descrito a seguir.

26. Em março de 2006, sobre o pagamento referente à Ordem de Serviço 01-MT e correspondente à Fatura nº 000340, da empresa Poliedro, o Ministério dos Transportes realizou uma glosa no valor de R$ 28.574,48 (vinte e oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) decorrente de uma reanálise dos termos do Contrato e Termo de Referência, onde se constatou um equívoco na interpretação dos textos, levando a uma forma de pagamento julgada incorreta. Segundo a nova interpretação, o pagamento deve ser efetuado com base nas horas efetivamente trabalhadas, implicando pagamentos por dias úteis, excluindo-se finais de semana e feriados, conforme declarado no Memorando nº 052/CGMI/SAAD/SE/MT (fls. 365/367, anexo 1, v. 1).

27. No ano seguinte, em setembro de 2007, foi realizada uma glosa no valor de R$ 14.829,12 (catorze mil, oitocentos e vinte e nove reais e doze centavos) em complemento àquela feita em março de 2006, cujo cálculo não considerou, no total descontado da Fatura nº 000340, o correspondente ao valor dos serviços cobrados à maior no próprio mês a que a fatura se referia (fls.368, anexo 1, v. 1).

28. Em relação às demais ordens de serviço, estas também estavam sendo pagas de acordo com a interpretação incorreta, considerando 22 dias úteis no mês, o que foi detectado e corrigido a partir do mês de junho de 2007, sem, contudo, haver, à época, revisão dos pagamentos efetuados desde o início do contrato até a referida correção.

29. Esses pagamentos indevidos foram apontados pela equipe do TCU que realizou auditoria na área de informática do Ministério dos Transportes, o que motivou o órgão a promover o levantamento em todos os processos de pagamentos referentes ao período de maio/2005 a abril/2007, acerca dos dias úteis trabalhados por técnicos da empresa contratada. Nesse trabalho, apurou-se uma diferença no valor total de R$ 105.081,68 (cento e cinco mil, oitenta e um reais e sessenta e oito centavos) a ser glosado (369/371, anexo1, v. 1).

30. Por meio da Carta nº 013/2007-CGMI/SAAD/SE/MT, de 25/09/2007, o Ministério dos Transportes comunicou o fato à Poliedro e concedeu-lhe 10 (dez) dias para que se manifestasse a respeito da memória de cálculo apresentada, não havendo, nos autos, referência alguma à existência de resposta da empresa contratada.

31. Cabe mencionar que os serviços vêm sendo pagos segundo a nova interpretação desde junho de 2007, ou seja, por hora de serviço efetivamente prestado, o que, segundo o Ministério dos Transportes, teve sempre o consentimento da empresa, haja vista em nenhum momento esta ter se manifestado de forma contrária às ações que foram tomadas e executadas pela Coordenação-Geral do Ministério (fls. 06/07, anexo 2).

32. Não obstante o exposto, em especial as glosas já efetuadas e o consentimento da empresa em relação à forma de pagamento considerando os dias úteis efetivamente ocorridos no mês de prestação do serviço, a Poliedro, nas suas razões de justificativas, manifestou-se contrária ao entendimento apresentado na Representação quanto à irregularidade da medição das horas constantes do faturamento e pagamento do Contrato nº 20/2005, no período de maio/2005 a junho/2005.

33. Em suas alegações, a Poliedro menciona a vinculação ao instrumento convocatório como princípio que perpassa a fase de licitação e insere-se no seio da execução contratual (fl. 155, anexo 2) com o intuito de respaldar legalmente a obrigatoriedade da adoção da unidade de medida de 176 horas mensal na execução do contrato, por força do item 9 do Termo de Referência do Contrato (fl. 21, anexo 1), transcrito a seguir.

'Para os serviços técnicos profissionais, será considerada a jornada de trabalho mensal de 176 (cento e setenta e seis) horas.'

34. A empresa afirma que 'no edital e no contrato consta cláusula impondo o parâmetro de remuneração de 176 horas'. Acrescenta que a situação analisada é exemplo de um costume administrativo profundamente arraigado na realidade dos órgãos públicos (fl. 121, anexo 2) e não pode uma mera conclusão interpretativa estabelecer um critério de remuneração distinto do estatuído no Edital e no Contrato, visto que isso seria impingir ao particular regra nova que consistiria na manutenção da equação econômica do contrato, o que só se admite na hipótese de aditivo ou justo motivo, mediante prévia anuência do particular (fl. 156, anexo 2).

35. As alegações trazem a consideração de que se o Tribunal entender que a metodologia determinada pelo Edital e pelo Contratado é contraproducente e afigura-se como

inadequada aos propósitos e interesses da Administração pública, deverá adotar medidas corretivas a serem aplicadas doravante, observando-se o mandamento constitucional da preservação das condições efetivas da proposta financeira apresentada por esta empresa (fl. 156, anexo 2).

Análise

36. Não se pode por em dúvida a vinculação ao edital como princípio básico de toda licitação, a que se sujeitam tanto os licitantes como a Administração (Lei nº 8.666/1993, arts. 3º e 41). Pela Lei de Licitações e Contratos, os contratos administrativos vinculam-se aos termos do edital e à proposta do licitante vencedor (art. 54, § 1º, e art. 55, inciso XI). Nesse sentido, a execução do Contrato nº 20/2005 deve observar, obrigatoriamente, as especificações constantes do Termo de Referência do Pregão nº 027/2004.

37. O Termo de Referência em questão cita, em vários pontos (itens 9 e 24.3), que 'será considerada a jornada de trabalho mensal de 176 (cento e setenta e seis) horas'. Esse preceito está inserido em tópicos que discorrem sobre a previsão da demanda de horas de prestação de serviços com a finalidade de dimensionar o volume dos serviços a serem contratados e seus respectivos valores. Trata-se de estimativa da demanda anual, conforme se verifica nos quadros acostados às folhas 21 e 36 do anexo 1, para cujo cálculo considerou-se a jornada de trabalho de 176 horas.

38. Nesse contexto, a jornada de trabalho adotada não impõe um parâmetro de remuneração, como interpreta a contratada, mas refere-se a um valor médio adotado para cômputo da estimativa da demanda dos serviços contratados. Essa demanda anual prevista para o contrato, para fins de pagamento, deve ser considerada exclusivamente como volume máximo dos serviços a serem prestados por ano de vigência do contrato.

39. Corroborando esse juízo, o item 9 do Termo de Referência estabelece que o pagamento mensal do contrato deve considerar somente os serviços efetivamente realizados em cada mês. Assim, embora seja prática comum o pagamento mensal de 176 horas por profissional alocado em contratos de natureza de locação de mão-de-obra, conforme colocação da Poliedro, para a correta execução dos contratos cujo pagamento se dá por horas de serviços prestados, é imprescindível o cômputo da quantidade exata de horas de serviços efetivamente prestados à administração, de acordo com o disposto na avença e no termo de referência.

40. Essa é a forma que os pagamentos do Contrato nº 20/2005 têm sido realizados desde junho de 2007, com base nas horas efetivamente trabalhadas, implicando em remuneração por dias úteis, excluindo-se finais de semana e feriados, sem conhecimento de divergência por parte da empresa até o momento desta Representação.

41. Dessa maneira, em consonância com o entendimento do Ministério dos Transportes, entende-se que os faturamentos e pagamentos relativos à execução correta do Contrato nº 20/2005 devem ser contabilizados mediante a apuração exata de horas de serviços efetivamente prestados, não se computando os dias não úteis, sendo devidos os valores pagos em desacordo com as regras editalícias de medição.

42. Diante do exposto, conclui-se que:

42.1. Não devem ser acatadas as razões de justificativas apresentadas pela empresa Poliedro;

42.2. Julgam-se indevidos os pagamentos realizados desde o início do contrato até maio de 2007 em desacordo com as regras editalícias de medição (horas de serviços prestados);

42.3. O Ministério dos Transportes deve glosar os pagamentos a maior em razão de despesas referentes a horas não trabalhadas relativas a faturas emitidas desde o início do contrato até maio de 2007.

IV - Dos efeitos financeiros referentes à repactuação contratual

***Ponto questionado**: A empresa Poliedro Informática e a Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério dos Transportes (SAAD/MT) realizaram, respectivamente, a solicitação e autorização de pagamento referente à repactuação do Contrato nº 20/2005, de efeitos financeiros retroativos a 01/05/2005, sem previsão legal que subsidie tal decisão, quando os efeitos da repactuação deveriam retroagir no máximo até 10/04/2007, data da solicitação da contratada.*

Razões de Justificativa dos responsáveis
Poliedro – Informática, Consultoria e Serviços Ltda.

43. De início, em suas justificativas, acostadas às folhas 131/153 do anexo 2 dos autos, a contratada expõe a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos como postulado constitucional e apresenta dispositivos legais correlatos e citações doutrinárias que asseguram essa harmonia contratual.

44. Refere-se, a entendimento deste Tribunal de Contas, no qual reconheceu que 'a imposição contra o Particular que contrata com a Administração Pública de suportar por até 12 (doze) meses as alterações de suas planilhas em decorrência da celebração de Acordo/Convenção/Dissídio Coletivo de Trabalho, representaria locupletação da Administração' (fl. 134, anexo 2) e, dessa maneira, a contratada não deve arcar com o ônus decorrentes desses acordos.

45. Por outro lado, trouxe julgado mais recente deste Tribunal, Acórdão nº 1563/2004-Plenário, admitindo que a ocorrência de acordo coletivo de trabalho não observa o prazo carencial de doze meses (fl. 134, anexo 2).

46. Em seqüência, a empresa faz referência a julgados, acórdãos do TCU e a doutrinadores (fls. 135/142, anexo 2) que, em síntese, amparam o repasse, por meio do instituto da repactuação, dos reajustes salariais concedidos às categorias de trabalhadores para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, e assentam a data a partir da qual se inicia o direito à repactuação contratual.

47. A contratada, com amparo da Decisão 467/2002–TCU–Primeira Câmara, acrescenta que a concessão do reajustamento do contrato com base na Convenção/Acordo Coletivo de Trabalho implica em revisão dos valores pagos.

'os reajustes salariais deflagrados por Acordos Coletivos homologados pela Justiça Trabalhista podem ser enquadrados, no entender da equipe, no que dispõe o art. 65, § 5º, acima. Ressalte-se, porém, que tal dispositivo prevê, como conseqüência, uma revisão de valores pagos,(...);

(...)

Fica, assim, como entendido pela equipe, validado o Parecer da CONJUR-MEC, uma vez que a Lei nº 8.666/1993 permite tanto a modificação de parâmetros e especificações de prestação de serviços e conseqüente modificação de valores pagos, como o reajuste desses valores a partir de Acordos Salariais Coletivos.'

48. Conforme juízo da Poliedro, o pagamento de diferenças, apuradas entre o valor faturado e o valor devido consoante aplicação dos índices de reajuste, nada mais é do que a compensação financeira entre os valores faturados sem o reajustamento e aqueles que eram devidos após aplicado o reajustamento, mas que, por força de lei, tiveram que aguardar o interstício de doze meses. Esse pagamento, segundo a empresa, é um direito garantido ao contratado e se constitui em reserva legal contra a ofensa ao princípio do enriquecimento sem causa por qualquer das partes contratantes.

49. Com o intuito de corroborar esse entendimento e defender a plena possibilidade do pagamento de diferenças residuais anteriores à celebração do termo aditivo, a contratada traz, em suas justificativas, os pareceres do MPU nos 094/2006 e 0159/2006 (fls. 145/147, anexo 2). O primeiro defende que um reajuste devido à uma data anterior à assinatura do termo aditivo deve ser feito mediante reconhecimento de dívida. O outro parecer, por sua vez, consigna a possibilidade da repactuação a partir da vigência do contrato e da vigência da nova convenção ou acordo coletivo.

50. Deve-se mencionar ainda as citações dos doutrinadores Celso Antônio Bandeira de Mello e Floriano Azevedo Marques Neto, trazidas pela contratada, acerca da pertinência e procedência do pagamento dessas diferenças, sob pena de enriquecimento sem causa e locupletação da Administração.

51. Em contraponto ao posicionamento da Sefti de que o pagamento de tais diferenças deve ser admitido somente após a data de solicitação do pedido de repactuação contratual, a empresa trouxe o julgado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), AC 1999.01.00.111803-4BA APELAÇÃO CIVEL, com o entendimento transcrito a seguir (fl. 147, anexo 2).

'A ausência de requerimento administrativo para a revisão do contrato não conduz à carência de ação.'

52. Ademais, mencionou outra ação do TRF1, cujo julgado, para o caso tratado, se

manifesta pela prescrição qüinqüenal dos pagamentos mensais de faturas resultantes da execução de contrato de prestação de serviços firmado entre a União e a Autora da ação (AC 1997.34.00.031549-7/DF APELAÇÃO CIVEL) (fl. 148, anexo 2).

53. Ante esses julgados, a Poliedro entende que não há que se falar em inércia por ausência de requerimento administrativo, sendo pertinente a postulação de repactuação fundada em convenção coletiva de trabalho, bem como o pagamento do passivo desde o momento do fato gerador, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da Administração (fl. 148, anexo 2).

54. Por fim, traz aos autos decisão do Superior Tribunal de Justiça, em que reconheceu o direito a Autora de receber os valores desde a primeira convenção coletiva, a partir da qual a União foi considerada inadimplente, como foi determinada a incidência de correção monetária aplicável sobre o passível desde a data do fato gerador, ou seja, a data das respectivas convenções coletivas de trabalho (fls. 152/153, anexo 2).

SAAD/MT

55. Para esclarecimento, a SAAD encaminhou o Despacho nº 1222/2007 (fls. 15/16, Anexo 2), o qual apresenta o Parecer nº 331 (fl. 18/46, Anexo 2) como resposta ao questionamento, ambos documentos exarados pela Consultoria Jurídica do Ministério dos Transportes – Conjur/MT.

56. No Parecer nº 331, a Conjur/MT argumenta que a repactuação ora em análise 'atende não só aos requisitos da legislação que rege a matéria, como também se amolda ao entendimento manifestado no Acórdão 1.563/2004–TCU–Plenário'. Defende, ainda, que, estando o Contrato em vigor, 'a partir de 01/05/2005, quando foi celebrada nova convenção coletiva reajustando o salário da categoria, a empresa passou a ser titular do direito à repactuação', independentemente do momento em que a solicitou e 'para que a demora em se efetuar o requerimento administrativo pudesse ter o condão de extinguir parcialmente os efeitos financeiros do direito à repactuação, haveria necessidade de lei prevendo expressamente essa situação'(fls. 22 e 24, anexo 2).

57. A Consultoria apresentou como precedente para a questão a decisão do Recurso Especial nº 554.375/RS do Superior Tribunal de Justiça, em que ficou estabelecido que o termo inicial a ser respeitado para manutenção do equilíbrio contratual é a data em que passou a viger as majorações salariais da categoria profissional que deu ensejo à revisão (fls. 26/28, anexo 2).

58. Citaram-se ainda os Acórdãos nºs 1.309/2006 e 1.116/2004, ambos da Primeira Câmara, os quais, segundo a Consultoria Jurídica do Ministério, consideraram regulares os efeitos retroativos à data-base da categoria, por entender que a repactuação decorre do contrato e não do termo aditivo (fls. 28/31, anexo 2).

59. Em contestação ao argumento de que a execução do contrato sem a repactuação durante 23 (vinte e três) meses demonstra a ausência de desequilíbrio econômico-financeiro, a Conjur/MT respondeu que o fato de a empresa ter executado o contrato sem receber os valores a título de repactuação não pode extinguir o seu direito. Segundo a área jurídica, é necessário considerar que há situações fáticas que muitas vezes inviabilizam a empresa de fazer o requerimento no momento em que lhe é reconhecido o direito à repactuação. Um exemplo seria o assincronismo entre a data-base da categoria e os dissídios coletivos, os quais, com freqüência, são firmados algum tempo depois da data-base e somente eles apresentam o instrumento necessário para a elaboração do requerimento, conforme a legislação pertinente (fl. 34, anexo 2).

60. A Consultoria argumenta que o parecer da auditoria interna do MPU trazido aos autos pela equipe de auditoria que formulou a representação não é o mais atualizado sobre o tema (fls. 35, anexo 2) e trouxe novos pareceres mostrando que o Ministério Público não apresenta entendimento pacífico acerca do assunto.

61. Na resposta a Conjur/MT disse não entender 'o motivo pelo qual o parecer por ela exarado foi qualificado como 'falho' e 'precário' pelos analistas, já que o assunto é controvertido e não há conformidade de entendimento sobre o tema' (fl. 37, anexo 2).

62. A referência à doutrina trazida aos autos por esta Secretaria na citação de José Cretella Júnior foi rebatida pela Conjur/MT com a argumentação que o normativo transcrito não se encontra vigente, tendo sido revogado pela Lei de Licitações (fl. 38, anexo 2).

63. Quanto à responsabilização dos Advogados da União em exercício na Consultoria Jurídica do Ministério dos Transportes, o corpo jurídico verificou ser 'despida de razoabilidade a tentativa de responsabilização dos Advogados da União desta Conjur/MT', pois o

'juízo de valor em relação ao comportamento e ao exercício do múnus público dos Advogados da União (ao contrário do que fora realizado pelos Analistas de Controle Externo da Sefti), somente poderia ser realizada pela Corregedoria-Geral da Advocacia-Geral da União, órgão competente para tal fim, nos termos da Lei Complementar nº 73/93' (fls. 40/43, anexo 2).

64. Por fim, ressaltou a Conjur/MT que a ela cabe 'emitir parecer conclusivo, não podendo omitir-se diante de uma situação, como a presente, em que não há regramento legal específico, nem pronunciamento do TCU' (fls. 43, anexo 2).

Análise

65. Inicialmente, faz-se oportuno referenciar o Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2005, cujo objeto é a repactuação de preços do Contrato conforme Convenção Coletiva de 2005 e 2006 e no qual consta a autorização para os pagamentos dos efeitos financeiros desse reajuste desde maio de 2005.

66. Porém, em vista da ocorrência de indícios de falhas na repactuação do Contrato nº 20/2005 apontada pela equipe de auditoria, por meio do Ofício de Requisição nº 06-568/2007, a Coordenação Geral de Recursos Logísticos (CGRL) orientou a SAAD para que, embora autorizado por meio de termo aditivo, fosse suspenso qualquer pagamento relacionado com repactuação até que se esclareça a questão (fls. 373/374, anexo 1, v. 1). Consoante consulta às Ordens Bancárias emitidas pelo órgão, realizada no Siafi, verificou-se que a SAAD acatou a orientação da CGRL (fls. 276/294, anexo 2, v. 1).

67. Cabe ressaltar que a questão em comento restringe-se à retroatividade dos efeitos financeiros da repactuação, não havendo controvérsia quanto à concessão de reajustamento do contrato administrativo com assento na convenção/acordo coletivo de trabalho, nem quanto à data inicial a partir da qual a empresa contratada tem direito à repactuação, qual seja 1º de maio de 2005.

68. Isso posto, verifica-se que a argumentação da contratada quanto ao direito à repactuação e à data em que se inicia esse direito, resumida nos itens 43 a 46, não apresenta dissonâncias com o entendimento exposto nesta instrução.

69. Para análise da questão, preliminarmente, faz-se conveniente trazer aos autos esclarecimentos acerca do instituto de repactuação exarado no relatório do Ministro-Relator do Acórdão nº 1.309/2006–TCU–Primeira Câmara:

'10.5. Repactuação, diferentemente dos demais institutos mencionados, não tem sede na Lei nº. 8.666/93, ao menos de forma expressa. Foi prevista pelo art. 5º do Decreto nº. 2.271/97, na esteira de uma série de medidas adotadas pelo governo para desindexar a economia. O aludido Decreto nº. 2.271/97 dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública Federal Direta, vedando a inclusão de disposições nos instrumentos contratuais que permitam a indexação de preços por índices gerais.

10.6. A melhor forma de interpretar a repactuação é como uma espécie do já mencionado instituto de reajuste, pois a repactuação também se destina a compensar o desequilíbrio econômico-financeiro resultante do aumento dos custos de execução do contrato causado pela inflação.

10.7. A diferença fundamental entre os dois institutos é que, enquanto no reajuste há correção automática do desequilíbrio, com base em índices de preços previamente estipulados no edital, na repactuação a variação dos componentes dos custos do contrato deve ser demonstrada analiticamente, de acordo com a Planilha de Custos e Formação de Preços e o contrato é corrigido na exata proporção do desequilíbrio que a parte interessada lograr comprovar. Outra distinção importante é que, diferentemente do que ocorre com o reajuste, a repactuação é aplicável exclusivamente naqueles contratos cujo objeto é a prestação de serviços executados de forma contínua.'

70. Igualmente apropriado é apresentar os fundamentos legais que definem e regem o instituto da repactuação, cujo objetivo é a adequação dos preços contratuais aos novos preços de mercado.

71. A Lei nº 8.666/1993 estabelece, em relação aos critérios de reajuste contratual, o que segue:

'Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

(...)

XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;'

72. Já o Decreto nº 2.271/1997, que dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, admite a possibilidade de repactuação contratual:

'Art. 5º Os contratos de que trata este Decreto, que tenham por objeto a prestação de serviços executados de forma contínua poderão, desde que previsto no edital, admitir repactuação visando a adequação aos novos preços de mercado, observados o interregno mínimo de um ano e a demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada.'

73. Por sua vez, a Instrução Normativa MARE nº 18/1997, que disciplina a contratação de serviços a serem executados de forma indireta e contínua, celebrados por órgãos ou entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG, sobre repactuação define:

'7. DA REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS

7.1 Será permitida a repactuação do contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data da proposta, ou da data do orçamento a que a proposta se referir, ou da data da última repactuação;

7.2. Será adotada como data do orçamento a que a proposta se referir, a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipações e de benefícios não previstos originariamente.

7.3. A repactuação será precedida de demonstração analítica do aumento dos custos, de acordo com a Planilha de Custos e Formação de Preços referida no subitem 1.1.5.'

74. O Tribunal de Contas da União, por seu turno, trata o tema no Acórdão nº 1.593/2004- Plenário, em que expede as seguintes orientações à Secretaria-Geral de Administração do TCU:

'9.1.3. no caso da primeira repactuação dos contratos de prestação de serviços de natureza contínua, o prazo mínimo de um ano a que se refere o item 8.1 da Decisão 457/1995 - Plenário conta-se a partir da apresentação da proposta ou da data do orçamento a que a proposta se referir, sendo que, nessa última hipótese, considera-se como data do orçamento a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipações e de benefícios não previstos originariamente, nos termos do disposto no art. 5° do Decreto 2.271/97 e do item 7.2 da IN/Mare 18/97;

9.1.4. no caso das repactuações dos contratos de prestação de serviços de natureza contínua subseqüentes à primeira repactuação, o prazo mínimo de um ano a que se refere o item 8.1 da Decisão 457/1995 - Plenário conta-se a partir da data da última repactuação, nos termos do disposto no art. 5° do Decreto 2.271/97 e do item 7.1 da IN/Mare 18/97;'

75. Diante dos normativos apresentados, constata-se que a repactuação contratual é legalmente prevista, podendo ser requerida pelo contratado, desde que observado o interregno mínimo de um ano, a partir da data da proposta, ou da data do orçamento a que a proposta se referir, ou da data da última repactuação. Contudo, quanto à data a partir da qual deverão valer os efeitos financeiros decorrentes da repactuação, a legislação é silente, não havendo, portanto, previsão legal para a retroatividade de pagamentos.

76. A Conjur/MT defende a retroatividade dos efeitos financeiros da repactuação do Contrato nº 20/2005 a 01/05/2005, data-base que ensejou o primeiro acordo coletivo ocorrido após a vigência do contrato.

77. A justificativa apresentada no item 56 para tal posicionamento não encontra respaldo nos dispositivos elencados anteriormente. A afirmação da Conjur/MT de que seria necessária a existência de lei prevendo a extinção do direito à retroatividade dos efeitos financeiros quando da repactuação contratual, não encontra suporte no princípio da legalidade, pelo qual deveria haver previsão legal para que se procedesse à retroatividade de pagamentos.

78. De acordo com o doutrinador Hely Lopes Meirelles (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 32. Ed. São Paulo: Ed. Malheiros Editora, 2006).

'A legalidade, como princípio da administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.

(...)

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza.'

79. Dessa forma, se não há dispositivo legal que expressamente autorize a retroatividade dos efeitos financeiros da repactuação contratual, o administrador público, por estar vinculado à lei, não pode, por si só, autorizá-la.

80. Quanto à decisão do STJ referente ao Recurso Especial nº 554.375/RS, citada pela Conjur/MT (item 57) e pela empresa Poliedro (item 54), há que se ressaltar que o acórdão daquela Corte partiu da premissa fática de que o contrato previa a aplicação da repactuação ante a ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis. Diante disso, entendeu que o deferimento da recomposição dos valores pela União apenas a partir do aditamento do contrato teria gerado uma espécie de ilícito contratual. Nota-se, portanto, que, no caso, o próprio contrato confundiu repactuação com reequilíbrio econômico-financeiro, que são institutos distintos.

81. A repactuação e o reequilíbrio possuem hipóteses de incidência e requisitos de aplicação totalmente diferentes. Enquanto o reequilíbrio é uma obrigação constitucional que sequer exige previsão contratual para sua aplicação, a repactuação é uma obrigação estritamente contratual, sendo necessário, inclusive, um acordo das partes sobre todos os seus termos para ser aplicada.

82. O acórdão do STJ entendeu que o caso de majoração salarial por meio de convenções coletivas seria causa de reequilíbrio econômico-financeiro, contrariando jurisprudência pacífica do próprio STJ (RESPs 134.797/DF, 41.1101/PR e 382.260/RS) e do TCU, pela qual entendem ser tal hipótese motivo para uma repactuação do contrato.

83. O fundamento básico da repactuação contratual é a bilateralidade, o interesse de ambas as partes em alterar o preço pactuado diante de uma necessidade superveniente. Tendo o acórdão abordado a questão sob a ótica do reequilíbrio econômico-financeiro, torna-se inviável utilizar os argumentos daquela decisão ao caso em questão, que trata apenas de repactuação.

84. Com o intuito de embasar seu posicionamento favorável à revisão dos valores pagos em decorrência de repactuação salarial, a Poliedro, em seus esclarecimentos, fez menção à Decisão 467/2002 – TCU – Plenário (item 47) e a pareceres do MPU. Ocorre que tal Decisão trata de uma situação analisada sob a ótica de entendimento já superado por este Tribunal, no qual os reajustes dos valores pagos se viabilizariam somente depois de decorrido o prazo de pelo menos um ano de vigência contratual. Ademais, de forma contrária ao entendimento da contratada, não há na Decisão determinação para que se efetue a revisão de valores pagos:

Decisão nº 467/2002-Plenário:

'8.1.5. avalie, em caso de reajustes salariais de categorias profissionais envolvidas em contratos de prestação de serviços, a conveniência e legalidade de alterações de valores pagos, para reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e da Decisão TCU nº 457/1995-Plenário, bem como a alternativa de alterações na logística da prestação desses serviços e conseqüente diminuição desses valores como compensação dos acréscimos salariais, à luz do mesmo dispositivo legal, desde que não haja comprometimento da qualidade, confiabilidade e efetividade dos serviços;'

85. Em relação aos pareceres do MPU citados pela Poliedro (nºs 094/2006 e 159/2006), esses não fazem alusão ao ponto central da questão, que é a data a partir da qual deveriam viger os efeitos financeiros da repactuação contratual. Como já descrito no item 49, um trata da forma como devem ser pagos os efeitos financeiros retroativos, sem expor fundamentação legal quanto à questão suscitada nesta instrução. O outro parecer trata da data em que se inicia o direito da contratada à repactuação. Desse modo, não há nas referências fundamentos que se aproveitem ao conflito em tela.

86. Também, em suas razões de justificativa, a Conjur/MT invocou os Acórdãos do TCU nos 1.309/2006 e 1.116/2004, ambos da Primeira Câmara (item 58). Da análise do Acórdão nº 1.309/2006, constata-se que o Tribunal reconheceu o direito do contratado à retroatividade dos efeitos financeiros à data do requerimento da repactuação e não à data-base da categoria, como alegado pela Consultoria do Ministério dos Transportes, pois se tratava de demora, por parte da Administração, no exame do pleito da contratada.

87. Já o Acórdão nº 1.116/2004, que trata de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão nº 147/2004–TCU–Primeira Câmara, não faz alusão à data de retroatividade de efeitos financeiros de repactuação contratual e, em sentido diverso ao defendido pela Conjur/MT, considera irregular a repactuação com a atribuição de efeitos retroativos:

'A periodicidade mínima para o reajuste de contratos, nos termos do art. 28 da Lei 9.069/95 e do art. 5º do Decreto 2.271/97, é de um ano. Por esses dispositivos, é nula de pleno direito e não surtirá efeito cláusula de correção monetária, cuja periodicidade seja inferior a um ano. Como corolário, <u>postergar a repactuação com a atribuição de efeitos retroativos incorre na mesma nulidade</u>.' (grifo nosso)

88. A Poliedro apresenta julgados do TRF1 como contra-argumentos ao entendimento da Sefti pela retroatividade dos pagamentos da repactuação à data da solicitação do pleito. O julgado AC 1999.01.00.111803-4BA APELAÇÃO CIVEL faz referência ao fato de que não há carência de ação pela ausência de requerimento administrativo para a revisão contratual. De fato, o direito ao requerimento da repactuação contratual se inicia, de acordo com a legislação, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data da proposta, ou da data do orçamento a que a proposta se referir, ou da data da última repactuação, sem limitação legal para a extinção desse direito durante a vigência do contrato, ou seja, uma vez adquirido o direito à repactuação, não há carência para sua interposição. Contudo, da ausência de prazo limite para o requerimento da repactuação, não se pode inferir a atribuição de efeitos retroativos à data em que se inicia o referido direito. Logo, o julgado não apresenta elementos capazes de contrapor o entendimento retro.

89. A outra ação do TRF1 referida pela Poliedro, AC 1997.34.00.031549-7/DF APELAÇÃO CIVEL, faz alusão à prescrição qüinqüenal de prestações devidas pela Fazenda. Replica-se a colocação com o fato de que o ponto abordado nesse tópico da instrução precede a questão da prescrição. O que está em discussão é a data a partir da qual a contratada tem direito ao pagamento das diferenças decorrentes do reajustamento dos valores contratuais, ou seja, data a partir da qual os valores são devidos. Portanto, não procede, no momento, a referência ao preceito da prescrição.

90. Em relação à alegação da Conjur/MT de que não há extinção do direito da contratada por ela ter executado o objeto sem receber os valores repactuados, justificando que podem ocorrer situações que a impeçam de requerer a repactuação tão logo nasça o direito, não há como considerar a retroatividade de pagamentos como direito inerente à empresa, visto que a legislação pertinente estabelece apenas a data em que se inicia o direito à repactuação, sendo omissa quanto aos seus efeitos financeiros. De acordo com o princípio constitucional da legalidade, o administrador público deve regrar-se pelo que determina a lei.

91. Ademais, entre o início da vigência do contrato e a data do requerimento da repactuação (23 meses), a contratada assinou termo aditivo, em abril de 2006, que prorrogava o Contrato nº 20/2005 (fls. 75/77, anexo 1) e que, conforme disposto na Cláusula Terceira, ratificava as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original, inclusive a sua Cláusula Nona, que define os preços para a execução do objeto.

92. Portanto, não cabe a alegação de desequilíbrio econômico-financeiro, haja vista que o preço inicialmente acordado foi formalmente ratificado pela contratada, a qual se comprometeu a dar continuidade à execução dos serviços por mais 12 meses, a despeito do prévio conhecimento dos novos valores pactuados no dissídio coletivo ocorrido em 2005, que onerou seus custos. É oportuno ressaltar que a prorrogação é ato bilateral, sendo esse o momento próprio para que as partes se manifestem quanto às condições contratuais.

93. A contratada defende que o pagamento dessas diferenças deve proceder desde o momento do fato gerador, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da Administração (itens 44 e 53). Ora, esta unidade técnica pondera que o enriquecimento sem causa tem três pressupostos : a ausência de justa causa, o locupletamento e o nexo de causalidade entre o enriquecimento e o empobrecimento. No caso, os requisitos não são preenchidos, tendo em vista que há sim justa causa para o indeferimento da repactuação retroativa.

94. O pedido de repactuação, assim como a demonstração analítica do aumento ou redução dos custos é ônus da parte que solicita, conforme se observa no item 'b' da cláusula quarta do contrato. Desse ônus a contratada não se desincubiu no momento oportuno, tendo em vista que apenas dois anos depois, inclusive após a própria prorrogação do contrato, veio solicitar a repactuação. É preciso que o pedido seja feito oportunamente para que a Administração possa analisar a conjuntura do mercado naquele momento e avaliar se, mesmo com a repactuação, aquele contrato mantém-se vantajoso.

95. O instituto da repactuação possui a característica contratual típica, pois exige sempre bilateralidade, de modo que só se efetua se houver concordância de ambas as partes. Essa bilateralidade impõe ônus para ambas as partes e o ônus da contratada era exatamente o de solicitar a repactuação quando se apresentasse a necessidade. Incabível falar-se em necessidade se a contratada cumpriu o contrato a contento e foi capaz de adimplir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, sociais e tributárias respectivas. Não cabia à Administração efetuar de ofício a repactuação, a esta cabe apenas fiscalizar o contrato, de modo a garantir que a contratada preste o serviço a contento e cumpra todas as suas obrigações, a fim de evitar qualquer responsabilização solidária ou mesmo subsidiária.

96. Nota-se que, no momento da prorrogação do contrato cabe à Administração observar se o contrato mantém-se ou não vantajoso. Para que o contrato mantenha-se vantajoso não basta que o preço seja compatível com os praticados no mercado, o valor deve continuar sendo exeqüível, ou seja, suficiente para que o contratante cumpra todas as suas obrigações, execute corretamente o contrato e obtenha lucro, fim primordial da atividade empresária. Tendo a Administração observado isso no momento da prorrogação do contrato, que, ressalte-se, foi expressamente aceita pela parte contrária, não há que se falar em enriquecimento ilícito.

97. Em relação à argumentação de que o parecer citado na representação não é o mais atualizado sobre a retroatividade dos efeitos financeiros da repactuação contratual, da análise dos pareceres do MPU mais recentes do que o mencionado na representação e trazidos aos autos pela Conjur/MT (fls. 35/37, anexo 2), constata-se que há divergência de entendimento acerca do tema, mostrando a falta de uniformização da matéria naquele órgão.

98. A respeito da contestação da Conjur/MT sobre a citação doutrinária de José Cetrella Júnior apresentada na representação, embora, de fato, o Decreto nº 2.300/1986 tenha sido revogado com a publicação da Lei de Licitações, e o artigo da Lei nº 8.666/1993 que previa a vedação da retroatividade dos efeitos financeiros nos contratos da Administração tenha sido vetado, não se pode concluir que a retroatividade está autorizada em todas as hipóteses. Ao contrário, pelo princípio da legalidade, a inexistência de dispositivo legal que autorize a retroatividade dos efeitos financeiros de repactuação contratual já é motivo suficiente para não concedê-la, visto que o administrador deve ter seus atos vinculados ao que a lei expressamente estabelece.

99. Na mesma linha do raciocínio defendido pela Sefti, existe decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, em que a Conselheira Marli Vinhadeli assim se pronunciou no voto da Decisão Ordinária nº 325/2007, Processo TCDF Nº 28882/2005:

'f) o prazo para pagamento dos novos valores repactuados deverá iniciar-se sempre a partir da conclusão das negociações, ou <u>no máximo poderá retroagir à data</u>

da solicitação do contratado;' (grifo nosso)

100. Conquanto a inexistência de dispositivo legal acerca do ponto em questão, um dos principais problemas da retroatividade dos efeitos financeiros relaciona-se à prorrogação da vigência do contrato. Para a prorrogação, o órgão deve realizar pesquisa de preço junto ao mercado com a finalidade de verificar se o preço do contrato vigente consiste ainda na proposta mais vantajosa para a Administração.

101. No caso de postergação da repactuação com efeitos financeiros retroativos, a pesquisa fica comprometida, pois são comparados preços de mercado, cujos valores já consideram as variações decorrentes de dissídios coletivos, com valores contratuais defasados. Nesse contexto, a postergação da repactuação contribui para a prorrogação contratual, propiciando a continuidade do vínculo da contratada com a Administração e comprometendo a validade da pesquisa realizada.

102. A postergação da repactuação somente seria aceitável no caso de assincronia entre a data-base da categoria e a data da celebração do acordo coletivo de trabalho, em que o interstício, para algumas categorias, pode ser de meses, ou no caso em que há atraso na disponibilização pública do termo do acordo. Nesses casos, a empresa fica impossibilitada de apresentar instrumento comprobatório do aumento de seus custos.

103. Apesar da retroatividade dos efeitos financeiros da repactuação não ser a regra, a Administração deve resguardar o direito legal da contratada quanto à adequação dos preços contratuais aos novos preços de mercado nas situações anteriormente descritas. Para tanto, quando existente cláusula contratual referente à repactuação de preços, deve-se incluir condição fixando prazo para que a contratada, uma vez de posse da demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada por meio da convenção coletiva de trabalho, solicite a repactuação com efeitos financeiros retroativos à data-base da categoria. No caso da não manifestação da contratada durante o prazo estabelecido, a retroatividade dos efeitos financeiros restringir-se-ia à data da solicitação.

104. Além disso, há que se ponderar que a retroatividade dos efeitos financeiros pode ocasionar outros problemas como, por exemplo, o comprometimento do planejamento do órgão e de sua execução orçamentária. A retroatividade, como regra a ser aplicada aos contratos administrativos, fere a segurança do direito da Administração, que poderia se ver diante de um requerimento de repactuação tendo transcorridos vários anos da vigência do contrato e, dessa forma, ser obrigada a arcar com desembolsos financeiros sem prévia provisão de recursos.

105. Assim, pelo princípio constitucional da legalidade, o administrador público deve reger seus atos segundo a legislação, e para que não realize a repactuação contratual com efeitos financeiros retroativos, não é necessária lei que a proíba, basta a inexistência de legislação que a autorize. Ademais, o administrador não pode se furtar ao dever de agir em consonância com o princípio da supremacia do interesse público, segundo o qual se deve interpretar a norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige e evite atos lesivos ao Erário.

106. Em síntese, esta unidade técnica conclui que os pagamentos dos efeitos financeiros decorrentes de repactuação contratual devem vigorar a partir da data da solicitação da contratada, podendo, excepcionalmente, em vista do assincronismo entre a data-base da categoria e a celebração dos dissídios coletivos, retroagir à data-base, desde que exista cláusula contratual que preveja essa situação e que estipule prazo para a manifestação da contratada, a partir da publicação do acordo coletivo.

107. Dessa forma, para o caso do Contrato nº 20/20005, frente à inexistência de cláusulas contratuais e de expressa autorização na legislação correlata, a retroatividade a 01/05/2005 dos efeitos financeiros em virtude da repactuação contratual não deve ser concedida, podendo se estender no máximo até a data da solicitação da contratada, qual seja 10/04/2007, rejeitando-se as razões de justificativas apresentadas pela Poliedro e pela Conjur/MT.

Da atuação da Conjur/MT

108. Quanto ao juízo de valor emitido na representação acerca do parecer exarado pela Conjur/MT, esse foi firmado ante o fato de a Consultoria ter fundamentado legalmente o direito à repactuação, contudo, sem mencionar dispositivos legais, jurisprudência, doutrina, decisões ou orientações que embasassem o direito aos efeitos financeiros retroativos, e dessa forma, sustentassem a opinião emitida.

109. Embora a Conjur/MT tenha questionado sua responsabilização em relação à autorização dos efeitos retroativos da repactuação do Contrato nº 20/2005 exarada por meio do

Parecer nº 205/2007 (fls. 239/248, anexo 1, v.1), este Tribunal entende ser passível a responsabilização de parecerista jurídico e de advogado público, desde que presentes condições específicas, conforme pode ser verificado nos seguintes Acórdãos:

Acórdão nº 462/2003–TCU–Plenário:

'O parecer jurídico emitido por consultoria ou assessoria jurídica de órgão ou entidade, via de regra acatado pelo ordenador de despesas, constitui fundamentação jurídica e integra a motivação da decisão adotada, estando, por isso, inserido na verificação da legalidade, legitimidade e economicidade dos atos relacionados com a gestão de recursos públicos no âmbito da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública federal, exercida pelo Congresso Nacional com o auxílio deste Tribunal, ex vi do art. 70 caput, e 71, II, da Constituição Federal.

(...)

Sempre que o parecer jurídico pugnar para o cometimento de ato danoso ao Erário ou com grave ofensa à ordem jurídica, figurando com relevância causal para a prática do ato, estará o autor do parecer alcançado pela jurisdição do TCU, não para fins de fiscalização do exercício profissional, mas para fins de fiscalização da atividade da Administração Pública.'

Acórdão nº 629/2004–TCU–Plenário:

'7.Relativamente à alegada contradição, sob o argumento de que este Tribunal firmou entendimento segundo o qual, 'quando o administrador age sob o entendimento de parecer jurídico, não se lhe deve imputar responsabilidade pelas irregularidades', há que se observar que esta Corte evoluiu, já há algum tempo, seu posicionamento no sentido de que tal entendimento somente pode ser admitido a partir da análise de cada caso, isto é, deve-se verificar 'se o parecer está devidamente fundamentado, se defende tese aceitável, se está alicerçado em lição de doutrina ou de jurisprudência'. Presentes tais condições, 'não há como responsabilizar o advogado, nem, em conseqüência, a autoridade que se baseou em seu parecer', conforme leciona a professora Maria Silvia Zanella Di Pietro (in 'Temas Polêmicos sobre Licitações e Contratos', Malheiros Editores, 2ª edição, 1995, pág. 118).'

110. O entendimento do Tribunal é corroborado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica no julgamento do Mandado de Segurança (MS) 24.584, em que o Supremo ratificou ato do Tribunal de Contas da União que responsabilizou procuradores federais por manifestações jurídicas proferidas no exercício de suas atribuições profissionais .

111. Portanto, uma vez que o parecer da Conjur/MT não apresenta tese aceitável quanto à retroatividade dos efeitos financeiros, nem fundamentação, doutrina ou jurisprudência, e sendo ato de pagamentos retroativos danoso ao Erário, este Tribunal de Contas entende que o parecerista jurídico é sim alcançado pela sua jurisdição, podendo ser responsabilizado por posicionamento proferido.

112. Urge frisar que, para o contrato em tela, não cabe, no momento, a responsabilização da Conjur/MT pela autorização dos pagamentos referentes à retroatividade dos efeitos financeiros da repactuação, haja vista não se ter concretizado dano ao Erário, devido às medidas tomadas por parte do Ministério dos Transportes, que, diante dos apontamentos da auditoria, ordenou a suspensão provisória desses pagamentos. Contudo, caso o Tribunal, posteriormente, venha a analisar o Contrato nº 20/2005 e constatar ato lesivo ao Erário, a Conjur/MT poderá sim ser responsabilizada pelos danos para os quais concorreu.

113. Ante a análise apresentada, conclui-se que:

113.1. De forma geral, no âmbito da Administração Pública, os pagamentos dos efeitos financeiros decorrentes de repactuação contratual devem vigorar a partir da data da solicitação da contratada, podendo, excepcionalmente, em vista do assincronismo entre a data-base da categoria e a celebração dos dissídios coletivos, retroagir à data-base, desde que exista cláusula contratual que preveja essa situação e que estipule prazo para a manifestação da contratada, a partir da publicação do acordo coletivo (item 106);

113.2. Não há respaldo legal para pagamentos retroativos a 01/05/2005 referentes à repactuação do Contrato nº 20/2005 (item 75);

113.3. A retroatividade dos efeitos financeiros da repactuação do Contrato nº 20/2005 deve se estender no máximo até a data da solicitação da contratada, qual seja

10/04/2007, haja vista que os atos emanados do administrador público devem vincular-se estritamente ao que determina a legislação, consoante o princípio constitucional da legalidade, não lhe cabendo autorizar a retroatividade de efeitos financeiros decorrente de repactuação contratual, conduta não pressentida nas normas legais aplicáveis (itens 105 e 107);

113.4. Os pareceristas jurídicos podem ser alcançados pela jurisdição do TCU quando esses elaborarem pareceres sem a devida justificativa, que não defendam tese aceitável, sem fundamentação alicerçada em doutrina ou jurisprudência, e pugnar para o cometimento de ato danoso ao Erário ou com grave ofensa à ordem jurídica (itens 109 a 111);

113.5. Devem ser rejeitadas as razões de justificativas apresentadas pela empresa Poliedro e pela Consultoria Jurídica do Ministério dos Transportes (item 107).

Conclusões

114. Dessa forma a Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação, conclui que:

I. Quanto às alíquotas cobradas e retidas a título de PIS:

a) Devem ser acolhidas as razões de justificativas apresentadas pela empresa Poliedro;

b) Consideram-se regulares as alíquotas cobradas e retidas a título de PIS, restando elidido o citado indício de irregularidade declarado na Representação.

II. Em relação às alíquotas cobradas a título de FGTS e Rescisão sem justa causa:

a) Consideram-se indevidos os pagamentos feitos pelo Ministério dos Transportes à empresa Poliedro a partir de 1º de janeiro de 2007 a título de FGTS e Rescisões sem justa causa, respectivamente em 8,5% e 4,25%, quando os percentuais destes encargos passaram a ser 8% e 4%;

b) O Ministério dos Transportes deve efetuar o cálculo e a glosa dos pagamentos efetuados a maior referentes às alíquotas de FGTS e Rescisão sem justa causa efetuados à empresa Poliedro;

c) O Ministério dos Transportes deve efetuar a revisão das alíquotas referentes ao FGTS previstas em todos seus contratos de prestação de serviços contínuos.

III. Quanto aos indícios de superfaturamento:

a) Não devem ser acatadas as razões de justificativas apresentadas pela empresa Poliedro;

b) Julgam-se indevidos os pagamentos realizados desde o início do contrato até maio de 2007 em desacordo com as regras editalícias de medição (horas de serviços prestados);

c) O Ministério dos Transportes deve glosar os pagamentos a maior em razão de despesas referentes a horas não trabalhadas relativas a faturas emitidas desde o início do contrato até maio de 2007.

IV. Em relação à retroatividade dos efeitos financeiros referentes à repactuação contratual:

a) De forma geral, no âmbito da Administração Pública, os pagamentos dos efeitos financeiros decorrentes de repactuação contratual devem vigorar a partir da data da solicitação da contratada, podendo, excepcionalmente, em vista do assincronismo entre a data-base da categoria e a celebração dos dissídios coletivos, retroagir à data-base, desde que exista cláusula contratual que preveja essa situação e que estipule prazo para a manifestação da contratada, a partir da publicação do acordo coletivo (item 106);

b) Não há respaldo legal para pagamentos retroativos a 01/05/2005 referentes à repactuação do Contrato nº 20/2005 (item 75);

c) A retroatividade dos efeitos financeiros da repactuação do Contrato nº 20/2005 deve se estender no máximo até a data da solicitação da contratada, qual seja 10/04/2007, haja vista que os atos emanados do administrador público devem vincular-se estritamente ao que determina a legislação, consoante o princípio constitucional da legalidade, não lhe cabendo autorizar a retroatividade de efeitos financeiros decorrente de repactuação contratual, conduta não pressentida nas normas legais aplicáveis (itens 105 e 107);

d) Os pareceristas jurídicos podem ser alcançados pela jurisdição do TCU quando esses elaborarem pareceres sem a devida justificativa, que não defendam tese aceitável, sem fundamentação alicerçada em doutrina ou jurisprudência, e pugnar para o cometimento de ato

danoso ao Erário ou com grave ofensa à ordem jurídica (itens 109 a 111);

e) Devem ser rejeitadas as razões de justificativas apresentadas pela empresa Poliedro e pela Consultoria Jurídica do Ministério dos Transportes (item 107).

Proposta de Encaminhamento

115. A representação em exame, desdobramento de fiscalização realizada no Ministério dos Transportes (Fiscalis nº 568/2007), apontou indícios de irregularidades no Contrato nº 20/2005 sobre os quais foi dada oportunidade à Subsecretaria de Assuntos Administrativos do MT e à empresa Poliedro Informática, Consultoria e Serviços Ltda. para esclarecerem os fatos. As razões de justificativa apresentadas, com exceção do item I , não elidiram as irregularidades indicadas.

116. A título de estimativa, tem-se o valor total devido de R$ 116.373,80 (cento e dezesseis mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta centavos), considerando-se que os pagamentos indevidos referentes a cobranças realizadas, desde o início do contrato até maio de 2007, em desacordo com as regras editalícias de medição (horas de serviços prestados) totalizam o valor de R$ 105.081,68 (cento e cinco mil, oitenta e um reais e sessenta e oito centavos), de acordo com levantamento realizado pelo Ministério dos Transportes (item 29), e que os valores devidos em razão das diferenças de percentuais cobradas e faturadas à título de FGTS e Rescisão sem justa causa desde janeiro de 2007 foram estimados em R$ 11.292,12 (onze mil, duzentos e noventa e dois reais e doze centavos) (item 22), conforme memória de cálculo constante do apêndice I desta Representação.

117. A esse total, deve ser acrescido o valor referente à economia oriunda da ação da Sefti em relação à irretroatividade dos efeitos financeiros da repactuação do Contrato nº 20/2005, cujo montante é estimado em R$ 512.744,05, resultando benefícios para a Administração Pública na ordem de R$ 629.117,85 .

118. Considerando-se que a vigência do Contrato nº 20/2005 extingue-se em 25/04/2008, sem possibilidade de novas prorrogações em virtude de determinação emanada do Acórdão nº 2.904/2005–TCU–Primeira Câmara e ratificada pelo Acórdão nº 1.312/2007–TCU–Primeira Câmara, e que a contratada ainda faz jus a três meses de pagamento (fevereiro, março e abril de 2008), cujo valor estimado é de R$ 666.347,00 (seiscentos e sessenta e seis reais, trezentos e quarenta e sete reais), consagrando a viabilidade da glosa dos pagamentos indevidos, esta Secretaria de Fiscalização de TI entende necessária a adoção de medida urgente que vise resguardar o Erário.

119. Em relação à Consultoria Jurídica do Ministério dos Transportes, que autorizou o pagamento dos efeitos financeiros retroativos, considerando que não foram encontrados indícios de má-fé na elaboração do Parecer nº 331/2007/AGU/CONJUR/MT (fls. 18/46, anexo 2) e considerando que o dano ao Erário não foi consumado, não se oferecerá encaminhamento relativo à Conjur/MT neste momento, sem prejuízo de eventual responsabilização em caso de futura apuração de débito.

120. Ante o exposto, a Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação propõe determinação para que o órgão realize a glosa dos valores devidos ao Erário, de forma a obter maior efetividade no ressarcimento dos valores, sem prejuízo de eventual instauração de Tomada de Contas Especial caso os valores apurados não sejam glosados tempestivamente.

121. Dessa forma, submetemos os autos à consideração superior propondo o que se segue:

I. Acolher as razões de justificativa apresentadas pela empresa Poliedro Informática, Consultoria e Serviços Ltda. quanto ao item I desta instrução, considerando regulares as alíquotas cobradas e retidas a título de PIS, sob os percentuais de 1,65% e 0,65%, respectivamente, tendo em vista o regime tributário sobre o lucro real adotado pela empresa e o disposto nas normas que regem a referida contribuição: arts. 30 e 31 da Lei nº 10.833/2003, art. 2º da Lei nº 10.637/2002, art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e os §§ 4º e 5º do art. 2º da IN/SRF nº 480/2004;

II. Rejeitar as razões de justificativa da Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério dos Transportes e da empresa Poliedro Informática, Consultoria e Serviços Ltda. quanto aos itens II, III e IV desta instrução;

III. Determinar à Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério dos Transportes, com fulcro no art. 71, inciso IX e §§ 1º e 2º, da Constituição Federal c/c art. 45 da Lei nº 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que aplique os exatos termos do Contrato nº 20/2005 conforme o art. 3º da Lei nº 8.666/1993, adotando as seguintes

providências:

a. Reduzir para 8% e 4%, nas planilhas de custo e formação de preços da contratada, os percentuais das parcelas referentes ao FGTS e às Rescisões sem justa causa, respectivamente, a partir de 01/01/2007, haja vista o término da vigência do § 2º do art. 2º da Lei Complementar nº 110/2001;

b. Efetuar, desde já, os pagamentos conforme as planilhas de custo e formação de preços corrigidas pelo item anterior;

c. Recalcular, conforme as planilhas de custo e formação de preços corrigidas, todos os pagamentos realizados anteriormente, efetuando a glosa dos valores pagos indevidamente nas próximas faturas;

d. Efetuar a glosa, nas próximas faturas, dos valores pagos indevidamente, no âmbito Contrato nº 20/2005, em razão de cobranças de horas não trabalhadas constantes das faturas emitidas desde o início do contrato até maio de 2007, que, conforme levantamento realizado pelo próprio órgão, totaliza uma diferença no valor de R$ 105.081,68 (cento e cinco mil, oitenta e um reais e sessenta e oito centavos);

e. Tornar nulo o ato do Subsecretário de Assuntos Administrativos, assinado em 02/08/2007, que autorizou a despesa referente ao pagamento retroativo da repactuação do Contrato n° 20/2005, por falta de amparo legal;

f. Elaborar novo ato em substituição ao referenciado no item anterior, abstendo-se de conceder efeitos financeiros retroativos à 01/05/2005 na repactuação do Contrato nº 20/2005, devido à falta de amparo legal, limitando a retroatividade, no máximo, à data da solicitação pela contratada, qual seja 10/04/2007;

g. Efetuar a revisão de todos seus contratos de prestação de serviços contínuos quanto às alíquotas cobradas à título de FGTS e Rescisões sem justa causa nas planilhas de custo e formação de preços;

IV. Determinar à Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério dos Transportes que apresente ao Tribunal, no prazo de 30 dias, os valores pagos e a forma de cálculo, demonstrando o método de quantificação dos valores e a comprovação da glosa referente a cada irregularidade apontada;

V. Determinar à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MP) que, ao prazo de 30 dias, oriente a Administração Pública na gestão dos seus contratos quanto às determinações contidas no acórdão que vier a ser proferido por este Tribunal, em especial quanto à ilegalidade à dos efeitos financeiros retroativos decorrentes de repactuação contratual."

8. O Sr. Diretor em substituição ratificou a instrução acima transcrita (fl. 45, v.p.).

9. O Sr. Secretário da Sefti, igualmente, manifestou-se de acordo com a instrução apresentada pela Sra. Analista (fl. 45, v.p.).

10. Em 18/3/2008, autorizei, em caráter excepcional e em homenagem aos princípios da verdade real, contraditório e ampla defesa, a juntada aos autos de documentação enviada pela Advocacia-Geral da União (anexo 4). Em acréscimo, determinei o encaminhamento dos autos à Sefti para que fossem verificados os reflexos dos documentos em questão no mérito desta Representação (fl. 46, v.p.).

11. Em instrução conclusiva, a Sefti assim se manifestou, *verbis* (fls. 47/49, v.p.):

"(...)

10. Nos esclarecimentos juntados aos autos, a AGU, preliminarmente, apresenta justificativas que a legitima a ofertar medidas defensivas em prol de seus membros (fls. 4/9, anexo 4), alguns deles considerados responsáveis, no âmbito da presente Representação, pela autorização de despesa retroativa referente à repactuação dos Contratos nºs 19/2005 e 20/2005.

11. Posteriormente, a AGU apresenta argumentos exclusivamente em relação ao mérito da retroatividade dos efeitos financeiros da repactuação. Tal assunto foi tratado em profundidade na instrução anteriormente mencionada.

12. Por não trazerem inovações às argumentações já encaminhadas pela Consultoria Jurídica do MT (Conjur/MT), a Sefti entende que a questão já está sendo adequadamente tratada na instrução que analisa as razões de justificativa da SAAD/MT, da Conjur/MT e da empresa Poliedro, e, portanto, nada tem a acrescentar.

Conclusão

13. O documento juntado aos autos pela AGU não trazem reflexos na análise do mérito desta Representação."

12. O Sr. Diretor em substituição e o Sr. Secretário da Sefti ratificaram a instrução acima (fl. 49, v.p.).

13. É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, insta destacar que a representação ora em exame atende aos requisitos de admissibilidade previstos pelo artigo 237, inciso V e § único, do RITCU c/c artigo 132, inciso V, da Resolução TCU nº 191/06, razão pela qual deve ser conhecida.

2. Versa este processo sobre representação formulada por equipe de auditoria deste Tribunal em decorrência de fiscalização realizada no Ministério dos Transportes, com o objetivo de avaliar a terceirização no setor de informática desse Ministério.

3. Segundo a equipe de auditoria, o Contrato nº 20/2005, firmado entre a União, por intermédio da Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério dos Transportes (SAAD/MT), e a empresa Poliedro Informática, Consultoria e Serviços Ltda., e cujo objeto é a contratação de empresa especializada no ramo de informática para executar os serviços de manutenção de sistemas de informática no âmbito do Ministério, estaria eivado das seguintes irregularidades:

(i) pagamentos contendo percentuais indevidos (1,65%) a título de PIS, enquanto que, conforme informações nas notas fiscais, a empresa retém 0,65% relativo a esse tributo, e devido a não-cumulatividade prevista na legislação, cabe à empresa o ônus de provar que arca com percentual superior a esse;

(ii) pagamentos contendo percentuais indevidos a título de FGTS e rescisões sem justa causa, respectivamente em 8,5% e 4,25%, quando, a partir de 1º de janeiro de 2007, os percentuais desses encargos passaram a ser 8% e 4%;

(iii) faturamentos e pagamentos realizados em desacordo com as regras editalícias de medição (horas de serviços prestados), pois em diversas faturas foram consideradas 176 horas de serviços prestados, o que equivale a 22 dias úteis, sendo que há meses em que não se atingiu essa quantidade de horas; e

(iv) pagamento referente à repactuação do Contrato nº 20/2005 com efeitos financeiros retroativos a 1/5/2005, sem previsão legal que subsidie tal decisão, sendo que os efeitos financeiros da repactuação deveriam retroagir, no máximo, a 10/4/2007, data da solicitação da contratada.

4. Após a instrução inicial, foi realizada a audiência da Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério dos Transportes (SAAD/MT), bem como da empresa Poliedro Informática, Consultoria e Serviços Ltda., para que se pronunciassem a respeito dos indícios de irregularidades acima mencionados.

5. A análise das razões de justificativa oferecidas pela SAAD/MT e pela empresa Poliedro é feita a seguir.

(i) pagamentos contendo percentuais indevidos (1,65%) a título de PIS, enquanto que, conforme informações nas notas fiscais, a empresa retém 0,65% relativo a esse tributo, e devido a não-cumulatividade prevista na legislação, cabe à empresa o ônus de provar que arca com percentual superior a esse;

6. Quanto a esta suposta irregularidade, a empresa Poliedro esclareceu que, por ser tributada sobre o lucro real, estaria obrigatoriamente enquadrada no regime não-cumulativo do PIS, que impõe a aplicação do percentual de 1,65% sobre a receita auferida.

7. Nesse caso, o percentual reservado ao PIS nas planilhas de custo e formação de preços, conforme expressamente determina o artigo 2º da Lei nº 10.637/02, seria 1,65%.

8. Em acréscimo, o artigo 30 da Lei nº 10.833/03 determina que os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de direito privado pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos à retenção na fonte da contribuição para o PIS/PASEP com o percentual de 0,65%, de acordo com o disposto no artigo 31 da mesma Lei.

9. Assim sendo, a empresa tributada pelo lucro real, como é o caso da empresa Poliedro, deverá recolher 1,65% referente à Seguridade Social, sendo que 0,65% desse percentual é retido na fonte na ocasião do pagamento pelo contratante. A diferença (1%) poderá ser abatida de créditos junto à Receita Federal, conforme permite a Lei nº 10.637/02, ou deverá ser recolhida aos cofres públicos.
10. Quanto a esta questão, portanto, a planilha de preço ofertada apresenta-se em conformidade com a legislação que rege a matéria, razão por que as justificativas oferecidas merecem ser acolhidas.

(ii) pagamentos contendo percentuais indevidos a título de FGTS e rescisões sem justa causa, respectivamente em 8,5% e 4,25%, quando, a partir de 1º de janeiro de 2007, os percentuais desses encargos passaram a ser 8% e 4%;

11. No que se refere a essa questão, invoco como razões de decidir as conclusões da Unidade Técnica às fls. 26/27, v.p.
12. O artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01 majorou a contribuição vinculada ao FGTS devida pelos empregados em 0,5%. Todavia, o § 2º do mesmo diploma legal estabeleceu que a contribuição majorada seria devida por 60 (sessenta) meses, a contar de sua exigibilidade (1/1/2002), sendo extinta, por conseqüência, em 1/1/2007. Ocorre que o Ministério dos Transportes continuou efetuando os pagamentos como se a majoração ainda estivesse em vigor.
13. O mesmo se aplica ao percentual de 0,25% referente a rescisões sem justa causa, percentual igualmente incorporado aos custos da prestadora de serviços em decorrência da Lei Complementar nº 110/01 e também não mais exigível a partir de janeiro de 2007.
14. Apesar de a SAAD/MT ter informado que as providências com vistas à obtenção da devolução dos valores devidos estavam sendo adotadas, bem como que a empresa contratada não impôs óbices à referida devolução, até o presente momento não há evidências de que as mencionadas glosas tenham sido realizadas.
15. Desse modo, não procedem as alegações oferecidas.

(iii) faturamentos e pagamentos realizados em desacordo com as regras editalícias de medição (horas de serviços prestados), pois em diversas faturas foram consideradas 176 horas de serviços prestados, o que equivale a 22 dias úteis, sendo que há meses em que não se atingiu essa quantidade de horas;

16. Consoante destacado pelo Ministério dos Transportes, desde junho de 2007, os serviços vêm sendo pagos por hora de serviço efetivamente prestado.
17. A empresa Poliedro, por sua vez, entende que os pagamentos devem ser realizados de acordo com o parâmetro previsto pelo edital (176 horas), independentemente das horas efetivamente trabalhadas.
18. Embora o instrumento convocatório disponha, em seu Termo de Referência, que "*será considerada a jornada de trabalho mensal de 176 (cento e setenta e seis) horas*", há que se observar que essa consideração é feita em tópicos que tratam da previsão da demanda de horas de serviços a serem prestados à Administração. A finalidade de tal previsão é tão somente dimensionar o volume de serviços a serem contratados e seus respectivos valores. Isso é o que se depreende do item 9 do Termo de Referência em questão, que estabelece que o pagamento mensal do contrato deve considerar apenas os serviços efetivamente realizados em cada mês.
19. Desse modo, os pagamentos relativos ao Contrato nº 20/2005 devem ser realizados com base nas horas de serviço efetivamente prestadas, não se computando os dias não úteis.
20. Logo, assiste razão à Sefti no sentido de considerar indevidos os valores pagos em desacordo com as regras editalícias de medição, qual seja: mediante a apuração exata das horas trabalhadas.

(iv) pagamento referente à repactuação do Contrato nº 20/2005 com efeitos financeiros retroativos a 1/5/2005, sem previsão legal que subsidie tal decisão, sendo que os efeitos financeiros da repactuação deveriam retroagir, no máximo, a 10/4/2007, data da solicitação da contratada;

21. A irregularidade em comento restringe-se à retroatividade dos efeitos financeiros da repactuação contratual, não havendo dúvida no que diz respeito à concessão de reajuste do contrato com base na convenção/acordo coletivo, tampouco quanto à data inicial a partir da qual a empresa contratada tem direito à repactuação, a saber, 1/5/2005.

22. Segundo a empresa Poliedro, a partir de 1/5/2005, quando foi celebrada nova convenção coletiva reajustando o salário da categoria, a empresa passou a fazer jus à repactuação, independentemente do momento em que a solicitou. Esse entendimento se justificaria pela necessidade de se manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa e locupletação da Administração.

23. Igualmente, a SAAD/MT, por meio de parecer exarado pela Consultoria Jurídica do Ministério dos Transportes (Conjur/MT), defende que o termo inicial a ser considerado para a manutenção do equilíbrio contratual é a data em que passou a viger as majorações salariais da categoria profissional que deu ensejo à revisão.

24. A Sefti, diferentemente, entende que, em face da inexistência de dispositivo legal que autorize a retroatividade dos efeitos financeiros da repactuação contratual, bem como da ausência de cláusulas contratuais nesse sentido, a retroatividade a 1/5/2005 não deve ser concedida, podendo tais efeitos serem estendidos, no máximo, até a data da solicitação por parte da contratada (no presente caso, 10/4/2007).

25. A Lei nº 8.666/93 prevê que o valor pactuado inicialmente entre as partes pode sofrer três espécies de alterações: reajuste (artigo 40, inciso XI), atualização financeira em decorrência de atraso no pagamento (artigo 40, inciso XIV, alínea "c") e reequilíbrio econômico-financeiro (artigo 65, inciso II, alínea "d").

26. O reajuste de preços, conforme previsto pelo artigo 40, inciso XI, da Lei nº 8.666/93, tem como idéia central a reposição da perda do poder aquisitivo da moeda por meio do emprego de índices de preços prefixados no contrato administrativo.

27. O reequilíbrio econômico-financeiro *stricto sensu*, por sua vez, trata do reestabelecimento da relação contratual inicialmente ajustada pelas partes, desde que a alteração tenha sido provocada por álea extraordinária superveniente ao originalmente contratado. Instituto previsto no artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº 8.666/93, é concedido ao contratado pela Administração, desde que se verifique a ocorrência das hipóteses específicas de sua admissibilidade apontadas pela lei.

28. Especificamente para os contratos administrativos de serviços contínuos na esfera federal, o Decreto nº 2.271/97 e a Instrução Normativa MARE nº 18, de 1997, apresentam a repactuação de preços como mecanismo para manter a relação econômico-financeira do contrato.

29. Vedada a inovação normativa por meio de decreto, nos termos do artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal, a repactuação contratual poderia, a princípio, ser considerada inconstitucional, sob o argumento de que o instituto não poderia ter sido criado por norma inscrita em decreto.

30. Entretanto, ao meu ver, por força da supremacia constitucional e da presunção de constitucionalidade das leis, é norma de hermenêutica constitucional que os atos normativos sejam interpretados conforme a Constituição. Nada obsta que o mesmo tipo de esforço possa ser feito para preservar a legalidade de atos regulamentares. Nesse sentido, a repactuação de preços não teria sido editada pelo Decreto nº 2.271/97 como figura jurídica autônoma, mas como espécie de reajuste de preços, a qual, ao contrário de valer-se da aplicação de índices de preços, adota apenas a efetiva alteração dos custos contratuais. Desse modo, não há se falar em inconstitucionalidade quanto ao aspecto previsto no artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal.

31. Essa linha de raciocínio baseia-se no contorno dado a esses institutos pelos dispositivos legais que os fundamentam. Consoante se mencionará de forma mais detalhada adiante, a repactuação de preços tem como requisitos, para a sua concessão, a necessidade de previsão contratual e interregno temporal mínimo (artigo 5º, *caput*, do Decreto nº 2.271/97 e item 7 da IN MARE 18/97), requisitos estes também presentes no reajuste de preços (artigo 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e artigo 3º, § 1º, da Lei nº 10.192/01). Ambos os institutos se destinam a recompor o desequilíbrio causado pelo aumento dos custos de execução do contrato causado pela inflação.

32. Consoante destacado no Voto condutor do Acórdão nº 1.309-TCU-1ª Câmara, *"a diferença fundamental entre os dois institutos é que, enquanto no reajuste há correção automática do desequilíbrio, com base em índices de preços previamente estipulados no edital, na repactuação a variação dos componentes dos custos do contrato deve ser demonstrada analiticamente, de acordo com a Planilha de Custos e Formação de Preços, e o contrato é corrigido na exata proporção do desequilíbrio que a parte interessada lograr comprovar. Outra distinção importante é que, diferentemente do que ocorre com o reajuste, a repactuação é aplicável exclusivamente naqueles contratos cujo objeto é a prestação de serviços executados de forma contínua"*.

33. Diante do exposto, o instituto da repactuação contratual, entendido como espécie

de reajuste, encontra seu fundamento legal nos artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93, *verbis*:

Lei nº 8.666/93

"Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, ***obrigatoriamente****, o seguinte:*

(...)

XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;"

"Art. 50. São ***cláusulas necessárias*** *em todo contrato as que estabeleçam:*

(...)

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;"

34. Contudo, o normativo que trata expressamente da repactuação contratual, como já dito, é o Decreto nº 2.271/97, que dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Senão vejamos:

Decreto nº 2.271/97

"Art. 5º Os contratos de que trata este Decreto, que tenham por objeto a prestação de serviços executados de forma contínua poderão, desde que previsto no edital, admitir repactuação visando a adequação aos novos preços de mercado, observados o interregno mínimo de um ano e a demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada."

35. Ao prever o instituto da repactuação, o artigo 5º do Decreto nº 2.271/97 regulamenta os citados artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93, nos casos de contratos que tenham por objeto a prestação de serviços executados de forma contínua, quando expressamente prevista essa espécie de reajuste no edital.

36. Como visto, o normativo que estabelece interregno mínimo de um ano para concessão de repactuação é o artigo 5º do mencionado Decreto. Mas é a IN MARE nº 18/97, que, ao disciplinar a contratação de serviços a serem executados de forma indireta e contínua, define serviços continuados como *"aqueles serviços auxiliares, necessários à Administração para o desempenho de suas atribuições, cuja interrupção possa comprometer a continuidade de suas atividades e cuja contratação deva estender-se por mais de um exercício financeiro"*.

37. Acrescente-se, ainda, que também é a IN MARE nº 18/97 que determina, em seu item 7, que o interregno de um ano começa a correr da data da proposta, da data do orçamento a que a proposta se referir ou da data da última repactuação. Também é esse normativo que permite a adoção, como data do orçamento, da data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta:

Instrução Normativa MARE nº 18/1997

7. DA REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS

"7.1 Será permitida a repactuação do contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data da proposta, ou da data do orçamento a que a proposta se referir, ou da data da última repactuação;

7.2. Será adotada como data do orçamento a que a proposta se referir, a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipações e de benefícios não previstos originariamente.

7.3. A repactuação será precedida de demonstração analítica do aumento dos custos, de acordo com a Planilha de Custos e Formação de Preços referida no subitem 1.1.5."

38. Observa-se, porém, que os normativos supracitados silenciam acerca da data a

partir da qual deverão valer os efeitos financeiros decorrentes da repactuação.

39. Feitas essas considerações iniciais, passemos à análise do ponto central da questão em tela, qual seja, a data a partir da qual devem viger os efeitos financeiros da repactuação contratual: se da data da celebração do novo acordo coletivo que alterou o salário da categoria profissional ou se da data da solicitação, pela empresa contratada, da repactuação contratual.

40. Vale mencionar que, quanto aos reajustes salariais concedidos por meio de dissídios coletivos ou equivalentes, este Tribunal pacificou entendimento no sentido de que, por ocasião das repactuações de contratos administrativos para a prestação de serviços de natureza contínua, deve ser observado o interregno de um ano da data do acordo que serviu de base para a proposta ou para a última repactuação (Acórdãos nº 1.563/2004-Plenário e 1.744/2003-2ª Câmara, dentre outros).

41. Todavia, esta Corte de Contas, nas ocasiões em que tratou do tema em comento, não abordou o aspecto relativo à fixação do termo *a quo* para a eficácia dos efeitos da repactuação de preços.

42. Quanto a essa questão, o entendimento exarado pela Unidade Técnica não me parece ser aquele que reflete o melhor encaminhamento a ser dado à matéria.

43. Em relação ao ponto em discussão no presente feito, um dos posicionamentos possíveis considera que a data do requerimento pela contratada, acompanhado da respectiva planilha de custos, definiria o momento a partir do qual seria devida, se aprovada pela Administração, a repactuação dos preços contratados.

44. Contudo, sendo a repactuação contratual um direito que decorre de lei (artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93) e, tendo a lei vigência imediata, forçoso reconhecer que não se trata, aqui, de atribuição, ou não, de efeitos retroativos à repactuação de preços.

45. A questão ora posta diz respeito à atribuição de eficácia imediata à lei, que concede ao contratado o direito de adequar os preços do contrato administrativo de serviços contínuos aos novos preços de mercado. Em outras palavras, a alteração dos encargos durante a execução contratual deve resultar na compatibilização da remuneração da contratada, de modo que se mantenha inalterada a equação financeira do ajuste. O direito à repactuação decorre de lei, enquanto que apenas o valor dessa repactuação é que dependerá da Administração e da negociação bilateral que se seguirá.

46. Assim, a partir da data em que passou a viger as majorações salariais da categoria profissional que deu ensejo à revisão, a contratada passou a deter o direito à repactuação de preços.

47. Vale destacar, ainda, que a repactuação de preços poderia dar-se mediante apostilamento, no limite jurídico, já que o artigo 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93, faz essa alusão quanto ao reajuste. Contudo, não seria antijurídico e seria, inclusive, mais conveniente que fosse aperfeiçoada por meio de termo aditivo, uma vez que a repactuação tem como requisitos a necessidade de prévia demonstração analítica quanto ao aumento dos custos do contrato, a demonstração de efetiva repercussão dos fatos alegados pelo contratado nos custos dos preços inicialmente pactuados e, ainda, a negociação bilateral entre as partes. E, para reforçar o entendimento ora exposto, vale mencionar que o referido termo aditivo teria natureza declaratória, e não constitutiva de direitos, pois apenas reconheceria o direito à repactuação preexistente.

48. De mais a mais, importa destacar que a IN MARE nº 18/97, como ato normativo integrante da legislação regulamentar, não pode ser interpretada de forma a atingir objetivos distintos dos princípios que regem a atuação administrativa, em especial o princípio da vedação do enriquecimento sem justa causa pela Administração em detrimento do particular contratado. E, sendo a vedação ao enriquecimento sem causa um princípio de direito, deve ser observado pela Administração Pública, em especial na execução de seus contratos.

49. Como é cediço, o contrato administrativo, por parte da Administração, destina-se ao atendimento do interesse público, mas, por parte do contratado, objetiva um lucro, por meio da remuneração consubstanciada nas cláusulas econômicas e financeiras. E esse lucro há que ser assegurado nos termos iniciais do ajuste, durante a execução do contrato, o que se dará por meio da preservação da relação inicial encargo/remuneração. Isso porque, se, de um lado, a Administração tem o poder de modificar o projeto e as condições de execução do contrato para adequá-lo às exigências supervenientes do interesse público, de outro, o contratado tem o direito de ver mantida a equação financeira originariamente estabelecida no ajuste diante de situações específicas que passam a onerar o cumprimento do contrato.

50. Portanto, em vista de todas as razões apresentadas, considero que a repactuação de preços, sendo um direito conferido por lei ao contratado, deve ter sua vigência reconhecida imediatamente desde a data da convenção ou acordo coletivo que fixou o novo salário normativo

da categoria profissional abrangida pelo contrato administrativo a ser repactuado.

51. Oportuno ressaltar a necessidade de a Administração contratante comparar as planilhas de custos e formação de preços fornecidas pela contratada no momento da apresentação da proposta e do requerimento de repactuação, com vistas a verificar se ocorreu ou não a efetiva repercussão dos eventos majoradores nos custos do pactuado originalmente.

52. Além disso, a Administração, por intermédio da negociação bilateral, deve envidar esforços no sentido de, sem prejudicar a adequada relação econômico-financeira do contrato, reduzir custos para a atividade administrativa, certificando-se de que os preços – caso aprovada a repactuação – encontram-se de acordo com os valores de mercado de modo a verificar se a contratação continua vantajosa para a Administração.

53. Insta ressaltar que esse entendimento não exclui a aplicação da Instrução Normativa nº 2, de 30/4/2008, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que dispõe sobre regras para a contratação de serviços continuados ou não, em especial de seu artigo 41, inciso III. Ao contrário, alinha-se às diretrizes ali contidas.

54. Ocorre que a hipótese ora sob exame apresenta algumas particularidades que impedem a ampla aplicação da tese até aqui exposta.

55. O Contrato nº 20/2005 foi firmado em **25/4/2005**. Decorrido o interregno de um ano da data do acordo que serviu de base para a proposta, **a partir de 1/5/2005**, data-base que ensejou o primeiro acordo coletivo ocorrido após a vigência do contrato, a contratada passou a deter o direito à repactuação de preços.

56. Em 2006, foi firmado o Terceiro Termo Aditivo, que teve por objeto a prorrogação do contrato por mais 12 (doze) meses – de **25/4/2006** a **25/4/2007** (fls. 269/270, anexo 2, v. 1). Segundo dispõe o artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, os contratos de prestação de serviços a serem executados de forma contínua poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a (60) sessenta meses.

57. A lei reconhece que a prorrogação pode acarretar a alteração das condições originais da contratação não apenas em relação aos prazos contratuais. Apesar de as cláusulas iniciais do contrato serem mantidas inalteradas, as cláusulas relacionadas aos preços podem ser revistas em respeito ao equilíbrio econômico-financeiro da contratação.

58. Nos termos acima expostos, considero que, nas hipóteses de prestação de serviços contínuos, cada prorrogação caracteriza um novo contrato. Uma vez assinado o termo aditivo, o contrato original não mais pode ser repactuado.

59. Desse modo, no momento da assinatura do Terceiro Termo Aditivo caberia à contratada, caso ainda não tivesse postulado, suscitar seu direito à repactuação, cujos efeitos retroagiriam à 1/5/2005, data-base que ensejou a celebração de novo acordo coletivo que alterou o salário da categoria profissional. Contudo, o que aconteceu foi tão somente a alteração do prazo contratual, ratificando-se todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original (fls. 269/270, anexo 2, v. 1).

60. Ao aceitar as condições estabelecidas no termo aditivo sem suscitar os novos valores pactuados no acordo coletivo, a empresa Poliedro deixou de exercer o seu direito à repactuação pretérita. Em outros termos, a despeito do prévio conhecimento da majoração salarial decorrente do acordo coletivo ocorrido em maio de 2005, a empresa contratada agiu de forma oposta e firmou novo contrato com a Administração por meio do qual ratificou os preços até então acordados e comprometeu-se a dar continuidade à execução dos serviços por mais 12 (doze) meses.

61. Por conseguinte, considero que a solicitação de repactuação contratual feita pela empresa Poliedro em 10/4/2007, com efeitos retroativos a 1/5/2005, encontra óbice no instituto da preclusão lógica. Com efeito, há a preclusão lógica quando se pretende praticar ato incompatível com outro anteriormente praticado. *In casu*, a incompatibilidade residiria no pedido de repactuação de preços que, em momento anterior, receberam a anuência da contratada. A aceitação dos preços propostos pela Administração quando da assinatura da prorrogação contratual envolve uma preclusão lógica de não mais questioná-los com base na majoração salarial decorrente do acordo coletivo ocorrido em maio de 2005.

62. *A contrario sensu*, ao se admitir que os efeitos da repactuação pudessem retroagir a períodos anteriores à data da assinatura do termo aditivo de prorrogação contratual, o juízo discricionário feito pela Administração acerca da conveniência e oportunidade em prorrogar o contrato (juízo este baseado na qualidade dos serviços prestados e na adequação dos preços até então praticados) restaria comprometido. É nesse sentido que o artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, ao dispor sobre a possibilidade de prorrogação dos contratos de prestação de serviços a serem executados de forma contínua, estabelece, como finalidade, a *"obtenção de preços e*

condições mais vantajosas para a administração".

63. Ressalto que a aplicação de um instituto processual tal qual a preclusão ao feito sob exame decorre do entendimento de que a execução de um contrato é um processo, composto por diversos atos, que concede direitos e impõe obrigações às partes.

64. Por outro lado, na data da solicitação da repactuação por parte da empresa Poliedro (10/4/2007), estava em vigor o Terceiro Termo Aditivo, cuja vigência abrangia o período de 25/4/2006 a 25/4/2007. Assim, tendo em vista que os efeitos da repactuação somente podem incidir sobre contrato em vigor, entendo que o termo *a quo* a ser adotado para a incidência dos efeitos da repactuação contratual solicitada deve ser **1/5/2006**, primeira data-base ocorrida após a vigência do Terceiro Termo Aditivo. A partir de 1/5/2006, portanto, a empresa contratada passou a deter direito à nova repactuação dos preços do contrato em vigor.

65. A adoção da data-base como termo *a quo* para a incidência dos efeitos da repactuação contratual justifica-se pelo fato de que, regra geral, os efeitos do acordo ou convenção coletiva de trabalho que dispõe sobre majoração salarial retroagem à data-base da categoria que deu ensejo à revisão.

66. Desse modo, considerando que, a partir da data-base, a empresa passa a arcar com o incremento dos custos da mão-de-obra ocasionado pela majoração salarial decorrente do acordo coletivo, a tese ora defendida encontra amparo nos princípios da justa correspondência das obrigações e da vedação ao enriquecimento sem causa, conforme já abordado nos itens 48 e 49 deste Voto.

67. Contudo, vale destacar a rara possibilidade de que, em situações diferenciadas, o sindicato da categoria profissional abrangida pelo contrato administrativo a ser repactuado pode optar por abrir mão dessa retroatividade, fazendo com que os efeitos da repactuação apenas vigorem a partir da data da conclusão do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho.

68. Oportuno mencionar, ainda, aquelas hipóteses em que as negociações para a celebração do acordo ou convenção de trabalho, ou a solução do dissídio coletivo eventualmente instaurado, se prolonguem por algum tempo após a data-base da categoria profissional abrangida pelo contrato administrativo e, nesse intervalo, a Administração convoque o contratado para uma prorrogação contratual.

69. Nesse caso, o contratado estaria impossibilitado de postular a repactuação contratual no momento da assinatura do termo aditivo, pois, segundo já mencionado, um dos requisitos para a repactuação é a necessidade de registro do acordo ou convenção coletiva de trabalho no Ministério do Trabalho. Assim, caberá ao contratado inserir no termo aditivo a ser celebrado cláusula por meio da qual resguarde seu direito à repactuação, a ser exercido tão logo disponha do instrumento relativo ao acordo ou à convenção devidamente registrado.

70. Reputo necessário, ainda, tecer um breve comentário acerca da atuação da Consultoria Jurídica do Ministérios dos Transportes no feito ora sob exame.

71. Segundo a Sefti, *"uma vez que o parecer da Conjur/MT não apresenta tese aceitável quanto à retroatividade dos efeitos financeiros, nem fundamentação, doutrina ou jurisprudência, e sendo ato de pagamentos retroativos danoso ao Erário, este Tribunal de Contas entende que o parecerista jurídico é sim alcançado pela sua jurisdição, podendo ser responsabilizado por posicionamento proferido"* (fl. 41, v.p.).

72. De fato, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, os pareceristas jurídicos podem ser alcançados pela jurisdição do Tribunal de Contas da União quando elaborarem pareceres sem a devida justificativa, que não defendam tese aceitável, sem fundamentação alicerçada em doutrina ou jurisprudência, e pugnarem para o cometimento de ato danoso ao erário ou com grave ofensa à ordem jurídica.

73. Entretanto, essa não é a situação retratada na Representação ora sob análise. Ao exarar o Parecer nº 205-2007/MT/CONJUR/CGTA (fls. 239/248, anexo 1, v. 1), a Conjur/MT defendeu tese jurídica baseada na legislação que rege a matéria. Conforme já mencionado, trata-se de tema bastante controverso, sendo que os normativos correlatos silenciam acerca da data a partir da qual deverão valer os efeitos financeiros decorrentes da repactuação. Assim, não há se falar, no presente caso, em eventual responsabilização de pareceristas jurídicos.

74. Por fim, merece destaque a observação feita pela Unidade Técnica de que, considerando-se que a vigência do Contrato nº 20/2005 extinguiu-se em 25/4/2008, sem possibilidade de novas prorrogações em virtude de determinação emanada do Acórdão nº 2.904/2005-TCU- 1ª Câmara e ratificada pelo Acórdão nº 1.312/2007-TCU-1ª Câmara, e que a contratada ainda faz jus a três meses de pagamento (fevereiro, março e abril de 2008), cujo valor estimado é de R$ 666.347,00 (seiscentos e sessenta e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais), está demonstrada a viabilidade da glosa dos pagamentos indevidos.

75. Consta dos autos, ainda, que, em vista do apontamento de indícios de falhas na

repactuação do Contrato nº 20/2005 expostos ao Ministério dos Transportes pela equipe de auditoria por meio do Ofício de Requisição nº 06-568/2007-Sefti, a Coordenação-Geral de Recursos Logísticos (CGRL) orientou a SAAD/MT para que, embora autorizado por meio de termo aditivo, fosse suspenso qualquer pagamento relacionado com a repactuação até que se esclarecesse a questão (fls. 373/374, anexo 1, v. 1). Consoante consulta efetuada no Siafi, pela Unidade Técnica, às ordens bancárias emitidas pelo órgão, verificou-se que a SAAD acatou a orientação da CGRL (fls. 276/294, anexo 2, v. 1).

76. Destaco que o Exmo. Ministro Aroldo Cedraz, após solicitar vista deste processo na Sessão Plenária de 18/6/2008, elaborou Voto Revisor por meio do qual manifesta, na essência, sua concordância com o entendimento ora exposto.

77. Nesse sentido, o Ministro Revisor destaca ser o direito à repactuação um direito intangível da contratada, não podendo a Administração Pública suprimi-lo unilateralmente. Ainda de acordo com o nobre Ministro, *"os princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público a que estão sujeitos os órgãos e entidades contratantes, c/c o silêncio do ordenamento jurídico brasileiro quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes de repactuações, não são suficientes para respaldar a tese de que é ilegal a concessão de efeitos retroativos a esse tipo de ajuste econômico-financeiro"*.

78. Ainda em linha de consonância com o entendimento descrito no presente Voto, o Ministro Aroldo Cedraz considera que, *"embora se trate de direito intangível, a repactuação não se caracteriza como direito indisponível, podendo a contratada, por conseguinte, dela abdicar. Aliás, foi exatamente o que ocorreu à época da terceira alteração do contrato 19/2005, ocorrida em 13/4/2006, quando a contratada, com exceção da vigência inicialmente acordada, ratificou as demais cláusulas até então vigentes, entre elas a que se refere aos preços originalmente pactuados para a execução do objeto"*. Destarte, o Ministro Revisor também reconhece como termo *a quo* para a incidência dos efeitos da repactuação contratual pleiteada a data de 1/5/2006, visto tratar-se da primeira data-base ocorrida após a vigência do Terceiro Termo Aditivo.

79. O Ministro Aroldo Cedraz, entende, no entanto, *"que a tese merece maior aprofundamento, de modo a evitar que seja invocada em todo e qualquer caso, principalmente pelo fato de não haver na jurisprudência deste tribunal qualquer deliberação na qual se tenha enfrentado a questão da legalidade da concessão de efeitos retroativos às repactuações"*. Assim, considerando que, dentre os requisitos para a concessão de efeitos retroativos, está a necessidade de que o pedido seja feito em prazo razoável pela contratada, o Ministro Revisor reputa importante que se busque um solução objetiva para a questão, *"especialmente em razão da subjetividade inerente à avaliação do que seja 'prazo razoável para protocolização do requerimento"*. A busca por essa solução objetiva, nas palavras do nobre Ministro, *"além de evitar tratamento anti-isonômico – tanto por parte do administrador, como por parte deste tribunal – entre contratos firmados pelo setor público com particulares, minimizaria eventuais conseqüências danosas ao Erário na hipótese de concessão de efeito retroativo à repactuação, a exemplo daquelas descritas pela Sefti e sintetizadas nos subitens 7.8 e 7.9 supra"*.

80. Desse modo, o Ministro Revisor propõe que, a exemplo da solução adotada pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, seja recomendado ao Ministério dos Transportes que limite a retroação dos efeitos financeiros aos casos em que a contratada tenha formalizado o pedido dentro de um prazo previamente estipulado no edital de licitação e/ou minuta de contrato que o acompanha, sob pena de não mais fazer jus a tais efeitos.

81. Restituídos os autos ao meu Gabinete e depois de ler atentamente as razões expostas pelo ilustre Ministro, peço vênia para manter o entendimento inicialmente exposto, sem prejuízo de tecer os comentários a seguir. Agradeço, desde logo, a importante colaboração do nobre Revisor no sentido encontrar o encaminhamento que melhor se ajusta aos fatos narrados no presente processo.

82. Como oportunamente ressalvou o Ministro Aroldo Cedraz, o feito ora sob exame reveste-se de extrema relevância, uma vez que a decisão que vier a ser exarada por este Tribunal poderá impactar sobremaneira a Administração Pública Federal com um todo, em especial no que se refere aos contratos administrativos que tenham por objeto a prestação de serviços executados de forma contínua.

83. Registre-se que não se antevê a possibilidade de que o raciocínio construído neste Voto possa vir a resultar em significativos gastos para a Administração em face de solicitações de repactuações contratuais pretéritas. Isso porque a tese que advogamos limita o exercício do direito à repactuação à data de prorrogação contratual.

84. Repito, conforme já explicitado, considero ser a repactuação contratual um direito que decorre de lei (artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93), com fundamento em

mandamento constitucional (artigo 37, inciso XXI), e que confere ao contratado a possibilidade de adequar os preços do contrato administrativo de serviços contínuos aos novos preços de mercado. Assim sendo, não vejo como a Administração possa restringir seu exercício por meio de um ato normativo ou de um contrato. Claro está, entretanto, que estamos falando de direitos disponíveis, passíveis de preclusão, tal como colocado no presente Voto.

85. Por outro lado, entendo que, de certa forma, a sugestão alvitrada pelo Ministro Revisor para que seja limitado, de forma prévia e expressa, o alcance retroativo da repactuação foi contemplada na proposta que ora submeto à apreciação deste Plenário.

86. Do que ressai do entendimento ora perfilhado, o prazo para que a contratada exerça, perante a Administração, seu direito à repactuação terá início, após observado o interregno mínimo de um ano, na data da homologação da convenção ou acordo coletivo que fixar o novo salário normativo da categoria profissional abrangida pelo contrato administrativo a ser repactuado (podendo ou não, como mencionado nos itens 65 a 69 deste Voto, retroagir à data-base que ensejar a celebração dos referidos instrumentos) e findará no momento da assinatura de novo termo aditivo. Ou seja, em termos gerais, o direito de repactuar surgirá quando ocorrer um aumento dos custos do contratado, devendo a repactuação ser pleiteada até a data da prorrogação contratual subseqüente.

87. Se o contratado não pleitear de forma tempestiva a repactuação e, por via de conseqüência, prorrogar o contrato sem realizá-la ou, ao menos, prevê-la expressamente, entendo que ocorrerá a preclusão do seu direito a repactuar.

88. Constata-se, por conseguinte, a existência de um prazo para o contratado formalizar seu pedido de repactuação, o que, ao meu ver, vai ao encontro da sugestão feita pela Ministro Revisor.

89. Ademais, na linha da proposta do eminente Ministro Aroldo Cedraz, nada impede que o edital deixe sempre claro o prazo acima referido, de forma a esclarecer ao contratado o período dentro do qual deverá exercer, tempestivamente, seu direito à repactuação contratual, podendo esta Corte exarar recomendação nesse sentido.

90. Ainda na esteira da preocupação preconizada pelo Ministro Aroldo Cedraz, reputo conveniente determinar ao Ministério dos Transportes que nas futuras licitações para contratação de serviços contínuos de mão de obra deixe assente nos editais a data a partir da qual deverá ser contado o interregno de 1 (um) ano para a primeira repactuação. Em regra, será a data base da categoria envolvida. Assim será possibilitado aos licitantes a elaboração de propostas uniformes, tendo como base pressupostos únicos devidamente divulgados.

91. Por fim, agradeço mais uma vez as sugestões, de forma (integralmente acolhidas) e de mérito, formuladas pelo Ministro Aroldo Cedraz na busca pelo melhor encaminhamento a ser dado à matéria versada nos presentes autos.

92. Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à deliberação deste Plenário.

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 27 de agosto de 2008.

BENJAMIN ZYMLER
Ministro-Relator

ACÓRDÃO Nº 1827/2008 - TCU – Plenário

1. Processo nº 027.973/2007-2
2. Grupo II – Classe de Assunto: VII – Representação
3. Interessados: Tribunal de Contas da União
4. Órgão: Ministério dos Transportes
4.1. Entidade contratada: Poliedro Informática, Consultoria e Serviços Ltda. (CNPJ nº 02.660.447/0001-12)
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler
5.1. Revisor: Ministro Aroldo Cedraz
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: Sefti
8. Advogado constituído nos autos: não há

9. Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos que versam sobre Representação formulada por equipe de auditoria deste Tribunal em decorrência de fiscalização realizada no Ministério dos Transportes, com o objetivo de avaliar a terceirização no setor de informática desse Ministério (Fiscalis nº 568/2007).

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:

9.1. conhecer da presente Representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 237, inciso VII e § único, do RITCU c/c artigo 132, inciso VII, da Resolução TCU nº 191/2006, e artigo 113, § 1º, da Lei nº 8.666/93, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;

9.2. com fulcro no art. 71, inciso IX e §§ 1º e 2º, da Constituição Federal c/c art. 45 da Lei nº 8.443/92 e com o art. 250, inciso II, do RITCU, determinar à Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério dos Transportes (SAAD/MT) que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação, aplique os exatos termos do Contrato nº 20/2005 conforme o art. 3º da Lei nº 8.666/93, adotando as seguintes providências:

9.2.1. efetue a glosa, nas próximas faturas, dos valores pagos indevidamente, no âmbito Contrato nº 20/2005, em razão de cobranças de horas não trabalhadas constantes das faturas emitidas desde o início do contrato até maio de 2007, que, conforme levantamento realizado pelo próprio órgão, totaliza uma diferença no valor de R$ 105.081,68 (cento e cinco mil, oitenta e um reais e sessenta e oito centavos);

9.2.2. reduza para 8% e 4%, nas planilhas de custo e formação de preços da contratada, os percentuais das parcelas referentes ao FGTS e às Rescisões sem justa causa, respectivamente, a partir de 1/1/2007, haja vista o término da vigência do § 2º do art. 2º da Lei Complementar nº 110/2001;

9.2.3. efetue, desde já, os pagamentos conforme as planilhas de custo e formação de preços corrigidas pelo subitem 9.2.2 supra;

9.2.4. recalcule, conforme as planilhas de custo e formação de preços corrigidas segundo os parâmetros mencionados no item 9.2.1, todos os pagamentos realizados anteriormente, efetuando a glosa dos valores pagos indevidamente nas próximas faturas;

9.2.5. adote as mesmas medidas constantes dos subitens 9.2.2 a 9.2.4 supra em relação aos demais contratos de prestação de serviços contínuos firmados no âmbito do Ministério dos Transportes;

9.2.6. torne nulo o ato assinado em 2/8/2007 pelo Subsecretário de Assuntos Administrativos, mediante o qual fora autorizada despesa referente ao pagamento, retroativo a 1/5/2005, da repactuação do Contrato nº 20/2005, ressalvada a possibilidade de elaboração de novo ato que reconheça, como marco inicial para a incidência dos efeitos da repactuação de preços, a data de 1/5/2006, primeira data-base ocorrida após a celebração do Terceiro Termo Aditivo;

9.2.7. compare as planilhas de custos e formação de preços fornecidas pela contratada no momento da apresentação da proposta e do requerimento de repactuação, com vistas a verificar se ocorreu ou não a efetiva repercussão dos eventos majoradores nos custos do pactuado originalmente;

9.2.8. envide esforços no sentido de, sem prejudicar a adequada relação econômico-financeira do contrato, reduzir custos para a atividade administrativa, certificando-se de que os preços – caso aprovada a repactuação – encontram-se de acordo com os valores de mercado de modo a verificar se a contratação continua vantajosa para a Administração;

9.3. determinar, ainda, à Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério dos Transportes (SAAD/MT) que:

9.3.1. apresente a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação, os valores pagos e a forma de cálculo, demonstrando o método de quantificação dos valores e a comprovação da glosa referente a cada irregularidade apontada;

9.3.2. efetue a revisão de todos seus contratos de prestação de serviços contínuos quanto às alíquotas cobradas à título de FGTS e rescisões sem justa causa nas planilhas de custo e formação de preços;

9.4. recomendar à Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério dos Transportes (SAAD/MT) que, em seus editais de licitação e/ou minutas de contrato referentes à prestação de serviços executados de forma contínua, deixe claro o prazo dentro do qual poderá o contratado exercer, perante a Administração, seu direito à repactuação contratual, qual seja, da data da homologação da convenção ou acordo coletivo que fixar o novo salário normativo da categoria profissional abrangida pelo contrato administrativo a ser repactuado até a data da prorrogação contratual subseqüente, sendo que se não o fizer de forma tempestiva e, por via de conseqüência, prorrogar o contrato sem pleitear a respectiva repactuação, ocorrerá a preclusão do seu direito a repactuar;

9.5. recomendar à Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério dos Transportes (SAAD/MT) que, em seus editais de licitação e/ou minutas de contrato referentes à prestação de serviços executados de forma contínua, deixe claro a data de referência que servirá para a contagem do interregno de 1 (um) ano para a primeira repactuação, data esta que, em regra, será a data base da categoria envolvida;

9.6. determinar à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MP) que, ao prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação, oriente a Administração Pública na gestão dos seus contratos, considerando as determinações e a recomendação contidas no presente Acórdão;

9.7. dar ciência da decisão que vier a ser proferida, bem como do Relatório e Voto que a fundamentarem, à Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério dos Transportes (SAAD/MT), à empresa Poliedro Informática, Consultoria e Serviços Ltda. e à Advocacia-Geral da União.

10. Ata n° 34/2008 – Plenário.
11. Data da Sessão: 27/8/2008 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1827-34/08-P.

13. Especificação do quorum:

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Marcos Vinicios Vilaça, Valmir Campelo, Guilherme Palmeira, Ubiratan Aguiar, Benjamin Zymler (Relator), Aroldo Cedraz (Revisor) e Raimundo Carreiro.

13.2. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Valmir Campelo.

13.3. Auditor convocado: Augusto Sherman Cavalcanti.

13.4. Auditores presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho.

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

BENJAMIN ZYMLER
Relator

Fui presente:

PAULO SOARES BUGARIN
Procurador-Geral, em exercício

GRUPO II – CLASSE VII – Plenário
TC-027.973/2007-2 (com 4 anexos, os dois primeiros deles com 1 volume cada)
Natureza: Representação.
Unidade Jurisdicionada: Ministério dos Transportes.
Interessado: Tribunal de Contas da União.
Advogado constituído nos autos: não há.

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL FUNDADA EM DISSÍDIO COLETIVO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA RECONHECIMENTO DO DIREITO À RETROAÇÃO.

1. A repactuação contratual representa direito intangível da contratada, constitucional e legalmente reconhecido, não podendo a Administração Pública suprimi-lo unilateralmente, sendo, inclusive, possível a atribuição de efeitos financeiros retroativos, retroação esta que, via de regra, alcança a data-base subseqüente ao recebimento da proposta, ao orçamento que serviu de base para a licitação, ou ao **dies a quo** referente aos efeitos financeiros da última repactuação.
2. Embora intangível, o direito à retroatividade dos efeitos financeiros da repactuação não é indisponível, podendo haver, por parte da contratada, renúncia tácita ou expressa.

VOTO REVISOR

Trata-se de representação encaminhada por equipe da auditoria deste tribunal, em decorrência de fiscalização realizada no Ministério dos Transportes com objetivo de avaliar a terceirização em seu setor de informática.

2. As irregularidades tratadas nestes autos cingem-se ao contrato 20/2005, firmado entre a União, por intermédio da Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério dos Transportes – SAAD/MT, e a empresa Poliedro Informática, Consultoria e Serviços Ltda., cujo objeto é a contratação de empresa especializada no ramo de informática para executar os serviços de manutenção de sistemas de informação no âmbito do Ministério dos Transportes.

3. A solicitação de vistas deste processo teve como objetivo possibilitar-me o empreendimento de mais detalhada análise com relação à repactuação do contrato 20/2005, mais precisamente quanto ao efeito retroativo que foi dado àquele ajuste financeiro, haja vista a potencial repercussão que o **decisum** a ser proferido nestes autos terá sobre a Administração Pública de um modo geral.

4. Inicialmente, importa traçar um breve histórico relacionado àquela avenca. Firmado em 25/4/2005, o contrato 20/2005 (fls. 60/74, anexo 1) foi objeto de aditivo em 13/4/2006, oportunidade em que se prorrogou sua vigência até 25/4/2007, ratificando-se as demais condições do ajuste (fls. 269/270, anexo 2, vol. 1).

5. Posteriormente, em decorrência de pedido de repactuação formulado em 10/4/2007 pela empresa Poliedro Informática, Consultoria e Serviços Ltda., foi autorizado pela SAAD/MT o pagamento das diferenças devidas à contratada, com efeitos financeiros incidentes desde 1º/5/2005, data-base da categoria dos trabalhadores envolvidos na prestação dos serviços objetos do contrato 20/2005.

6. A retroação dos efeitos financeiros desse ajuste foi considerada indevida pela Secretaria

do TCU responsável pela Fiscalização de Tecnologia da Informação – Sefti, ensejando o chamamento aos autos, em sede de audiência, da SAAD/MT e da empresa Poliedro Informática, Consultoria e Serviços Ltda., as quais, em resposta, apresentaram razões de justificativa, argumentando, em síntese, que:

6.1. a repactuação ora em análise atende não só aos requisitos da legislação que rege a matéria, como também se amolda ao entendimento manifestado nos acórdãos 1.563/2004-Plenário, 1.309/2006 e 1.116/2004, ambos de 1ª Câmara, na decisão do Recurso Especial 554.375/RS do Superior Tribunal de Justiça – STJ, e em julgados do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF/1ª Região;

6.2. com a celebração de nova convenção coletiva de trabalho, em 1º/5/2005, reajustando o salário da categoria, a empresa passou a ser titular do direito à repactuação, independentemente de tê-la solicitado apenas em 10/4/2007, eis que somente na hipótese de haver expressa previsão legal nesse sentido a demora em se efetuar o requerimento administrativo teria o condão de extinguir parcialmente os efeitos financeiros do direito àquele ajuste financeiro;

6.3. há situações fáticas que muitas vezes inviabilizam a empresa de fazer o requerimento no momento em que lhe é reconhecido o direito à repactuação, a exemplo do que se verifica quando há assincronismo entre a data-base da categoria e o dissídio coletivo correspondente, este imprescindível para a elaboração do requerimento;

6.4. a não-retroação do reajuste caracterizaria enriquecimento ilícito da União, uma vez que os serviços foram prestados por profissionais remunerados em patamares incompatíveis com os valores pagos à contratada após 1º/5/2005.

7. A Sefti, refutando os argumentos apresentados pela SAAD/MT e pela empresa Poliedro Informática, concluiu que os efeitos financeiros decorrentes de repactuação contratual devem vigorar a partir da data da solicitação da contratada, podendo, excepcionalmente, em vista do assincronismo entre a data-base da categoria e a celebração do dissídio coletivo, retroagir à referida data-base, desde que exista cláusula contratual que preveja essa situação e que estipule prazo para a manifestação da contratada, a partir da publicação do acordo coletivo. Em respaldo a esse entendimento, a Sefti sustentou, entre outros, que:

7.1. ao passo que há previsão legal para a repactuação contratual, a legislação é silente quanto à data a partir da qual deverão valer os efeitos decorrentes desse ajuste financeiro, não sendo possível, portanto, a retroatividade de pagamentos, haja vista a sujeição do administrador público ao princípio constitucional da legalidade;

7.2. milita, ainda, em favor dessa tese o princípio da supremacia do interesse público, segundo o qual a norma administrativa deve ser interpretar da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, evitando atos lesivos ao Erário;

7.3. aquela mesma sujeição do administrador público ao princípio constitucional da legalidade evidencia ser infundado o argumento de que, para prevalecer o entendimento da unidade técnica, seria necessária a existência de lei prevendo a extinção do direito à retroatividade dos efeitos financeiros atinentes à repactuação contratual;

7.4. os acórdãos 1.309/2006 e 1.116/2004, ambos da 1ª Câmara do TCU, não se amoldam ao presente feito, eis que, naquela primeira deliberação, o tribunal, em face de demora por parte da Administração Pública no exame do pleito da contratada, reconheceu o direito à retroatividade dos efeitos financeiros à data do pedido de repactuação, e não à data-base da categoria; ao passo que o acórdão 1.116/2004, além de não fazer alusão ao termo **a quo** atinente aos efeitos financeiros da repactuação, considerou irregular a autorização de pagamentos retroativos baseados nesse tipo ajuste contratual;

7.5. o julgado do STJ invocado pelos defendentes também não se aplica ao caso em estudo, uma vez que, contrariando a jurisprudência do TCU e daquela própria corte judicial, considerou que a majoração salarial resultante de convenção coletiva de trabalho seria causa de reequilíbrio econômico-financeiro, e não de repactuação;

7.6. as deliberações do TRF/1ª Região não apresentam elementos que sustentem o entendimento de que seja legal, no caso em estudo, a retroação dos efeitos financeiros da repactuação ao dia em que se inicia o referido direito, ou seja, à data-base da categoria;

7.7. some-se à impossibilidade legal de se celebrar repactuação com efeitos **ex tunc**, o

fato de que, entre o início da vigência do contrato e a data do requerimento do ajuste financeiro – 25/4/2005 e 10/4/2007, respectivamente –, os contraentes, mediante termo aditivo firmado em abril de 2006, prorrogaram o contrato 20/2005 por mais doze meses, ratificando as demais cláusulas e condições estabelecidas no ajuste original, entre as quais a cláusula nona, que define os preços para a execução do objeto;

7.8. existe decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, no sentido de que "*o prazo para pagamento dos novos valores repactuados deverá iniciar-se sempre a partir da conclusão das negociações, ou no máximo poderá retroagir à data da solicitação do contratado*" (decisão ordinária 325/2007, processo TCDF-28.882/2005);

7.9. considerando que, para a prorrogação da vigência do contrato, o órgão/entidade contratante, a fim de verificar se a hipótese representa vantagem para a administração, deve realizar pesquisa de preço junto ao mercado, evidencia-se que a retroatividade dos efeitos financeiros da repactuação poderia tornar a prorrogação economicamente prejudicial para a Administração Pública, supervenientemente à referida prorrogação contratual;

7.10. a repactuação com efeitos retroativos tem, ainda, como conseqüência danosa à Administração Pública a dificultação do planejamento e da execução orçamentária da contratante, sem contar a dificuldade de se examinar, a destempo, a validade da demonstração analítica apresentada pela contratada em respaldo a seu pedido, exame este que deve ter por base a conjuntura do mercado existente à época a partir da qual a repactuação produzirá efeitos financeiros;

7.11. não há que se falar em aumento patrimonial injustificado por parte da União, uma vez que a ilegalidade da retroação é motivo suficiente para seu indeferimento, de modo que resulta afastado um dos pressupostos imprescindíveis à caracterização do enriquecimento ilícito, qual seja, a ausência de justa causa;

7.12. a espécie de reajuste em comento possui característica contratual típica, exigindo sempre bilateralidade, significando, entre outros, imposição de ônus para ambas as partes, sendo obrigação da contratada solicitar a repactuação quando se mostrar necessário, o que somente se verificou em 10/4/2007;

8. Por sua vez, segundo se depreende do voto que disponibilizou aos demais ministros antes da sessão plenária de 18 de junho do corrente ano, o eminente relator, ministro Benjamin Zymler, concluiu, em tese, pela possibilidade de se conceder efeitos retroativos às repactuações, de modo que o termo **a quo** dessa espécie de ajuste, ao contrário do que defendeu a Sefti, não seria necessariamente a data em que a contratada formulou o pedido junto à SAAD/MT, podendo se estender à data-base referente ao primeiro acordo coletivo ocorrido após a vigência do contrato, respeitados, obviamente, os normativos que regem a matéria.

9. Por outro lado, o eminente relator ressalvou que, até 13/4/2006 – momento da assinatura do terceiro termo aditivo, mediante o qual se prorrogou a vigência do contrato, ratificando-se as demais cláusulas daquele instrumento –, caberia à contratada, caso ainda não tivesse postulado, suscitar seu direito à repactuação, cujos efeitos retroagiriam à 1º/5/2005. Ainda segundo o ministro-relator, ao não tomar tal providência, o pedido de repactuação com efeitos retroativos a 1º/5/2005 passou a encontrar óbice no instituto da preclusão lógica, somente sendo possível adotar, como termo **a quo** para a incidência dos efeitos da repactuação pleiteada, a primeira data-base ocorrida após a vigência do terceiro termo aditivo, qual seja, 1º/5/**2006**.

10. Em meu entendimento, assiste razão ao nobre relator quando defende a possibilidade de se atribuir efeitos financeiros retroativos em caso de repactuação, retroação esta que, via de regra, alcança a data-base subseqüente ao recebimento da proposta, ao orçamento que serviu de base para a licitação, ou ao **dies a quo** referente aos efeitos financeiros da última repactuação.

11. Trata-se, conforme destacou o ministro Benjamin Zymler, de direito assegurado à empresa contratada, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e do art. 40, inciso XI, da Lei 8.666, de 21/6/1993. O aludido direito, aliás, é classificado pela doutrina administrativista e pela jurisprudência pátria como direito intangível, não podendo a Administração Pública suprimi-lo unilateralmente.

12. Ademais, com as vênias de estilo por dissentir da Sefti e de alguns administrativistas que compartilham o raciocínio exposto pela unidade técnica, entendo que os princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público a que estão sujeitos os órgãos e entidades

contratantes, c/c o silêncio do ordenamento jurídico brasileiro quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes de repactuações, não são suficientes para respaldar a tese de que é ilegal a concessão de efeitos retroativos a esse tipo de ajuste econômico-financeiro.

13. Tal raciocínio, a meu ver, desconsidera outro princípio, tão importante quanto aqueles outros dois, qual seja, o da impossibilidade de enriquecimento ilícito da União, insculpido, entre outros, na própria Constituição Federal (art. 37, inciso XXI) e na Lei 8.666/1993 (arts. 40, inciso XI, e 65, inciso II, alínea **d**, e §§ 5º e 6º), objetivando, em favor dos contratados, a garantia à manutenção das condições efetivas da proposta.

14. Em reforço a essa tese, lanço mão das palavras de Dalton Santos Morais (**in** Temas de Licitação e Contratos Administrativos, Editora NDJ Ltda., 2005, p. 131/132). Segundo esse autor, "*a IN/MARE nº 18/97, como ato normativo integrante da legislação regulamentar, não pode ser interpretada de forma a atingir objetivos distintos dos princípios que regem a atuação administrativa, em especial o princípio da vedação do enriquecimento sem causa pela Administração em detrimento do particular contratado.*" Dando continuidade ao raciocínio e escorado no mesmo princípio de direito, o autor assevera que "*poderá a Administração Pública contratante fixar como início da eficácia dos efeitos da repactuação a data de requerimento da contratada ou a data inicial de vigência dos salários normativos em relação aos quais se realiza a repactuação, desde que, ante a natureza jurídica de negociação bilateral da repactuação de preços, tenha sido o requerimento feito em prazo razoável pela contratada.*" (op. cit., p. 134)

15. No caso da repactuação em estudo, mostra-se evidentemente desarrazoado a aplicação de efeitos retroativos à 1º/5/2005, eis que o pedido somente foi formulado pela contratada em 10/4/2007, mais de 18 meses após a convenção coletiva vigente entre 1º/5/2005 e 30/4/2006 (fls. 210/220, anexo 1, vol. 1).

16. Outrossim, embora se trate de direito intangível, a repactuação não se caracteriza como direito indisponível, podendo a contratada, por conseguinte, dela abdicar. Aliás, foi exatamente o que ocorreu à época da terceira alteração do contrato 20/2005, ocorrida em 13/4/2006, quando a contratada, com exceção da vigência inicialmente acordada, ratificou as demais cláusulas até então vigentes, entre elas a que se refere aos preços originalmente pactuados para a execução do objeto.

17. Nessas circunstâncias, segundo destacou o ministro-relator Benjamin Zymler, 1º/5/**2006** – e não 1º/5/**2005** – deve ser reconhecido como termo **a quo** para a incidência dos efeitos da repactuação contratual pleiteada, haja vista se referir à primeira data-base ocorrida após a vigência do terceiro termo aditivo.

18. Apesar de razoável e coerente o encaminhamento adotado pelo eminente relator frente ao caso concreto objeto desta representação, entendo que a tese merece maior aprofundamento, de modo a evitar que seja invocada em todo e qualquer caso, principalmente pelo fato de não haver na jurisprudência deste tribunal qualquer deliberação na qual se tenha enfrentado a questão da legalidade da concessão de efeitos retroativos às repactuações.

19. Da transcrição empreendida no item 14 deste voto, extrai-se que o doutrinador citado aponta como requisito para a concessão de efeitos retroativos a necessidade de que o pedido de repactuação tenha sido feito em prazo razoável pela contratada. Embora concorde que a demora injustificada para a formalização do pedido configure renúncia tácita ao direito de retroação dos efeitos financeiros do ajuste pleiteado, considero temerário deixar de buscar uma solução objetiva para o problema, especialmente em razão da subjetividade inerente à avaliação do que seja "*prazo razoável para protocolização do requerimento*".

20. Tal busca por uma solução objetiva, além de evitar tratamento anti-isonômico – tanto por parte do administrador, como por parte deste tribunal – entre contratos firmados pelo setor público com particulares, minimizaria eventuais conseqüências danosas ao Erário na hipótese de concessão de efeito retroativo à repactuação, a exemplo daquelas descritas pela Sefti e sintetizadas nos subitens 7.9 e 7.10 supra.

21. Em pesquisa a editais de licitação que tratam expressamente do tema repactuação, constata-se que o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE tem fixado prazo para que a contratada solicite a repactuação, sob pena de não mais fazer jus à retroação dos efeitos financeiros. Como exemplo, cito o pregão eletrônico 20/2007 e os pregões presenciais 4/2008 e 5/2008, este último com sua minuta de contrato parcialmente transcrita abaixo:

"**CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO**

Os preços contratados poderão ser reajustados mediante solicitação da adjudicatária, observado o interregno mínimo de um ano, contada da data limite para a apresentação da proposta ou do último reajuste, com base na variação de custos ocorrida no período, desde que devidamente justificada e demonstrada em planilha.

Parágrafo Primeiro: Os componentes de custos apresentados em planilha, por ocasião da abertura da licitação, serão referências para a análise de reajuste, não sendo admitida a inclusão de qualquer elemento de custo que não esteja nos componentes apresentados inicialmente, salvo os decorrentes da Lei nº 8.666/93 ou outros atos normativos.

Parágrafo Segundo: A Adjudicatária não fará jus a repactuação com efeitos retroativos se não apresentar a solicitação de reajustamento contratual dentro do primeiro mês contados da data da homologação da Convenção Coletiva, tornando-se a única e exclusiva responsável pelos prejuízos decorrentes da não apresentação da solicitação no prazo informado." (destaque não consta no original)

22. O Banco da Amazônia S.A. – Basa, também fixa critérios para fins de repactuação, a exemplo do que se verifica na concorrência 2008/010 e nos pregões eletrônicos 2008/031 e 2008/033, este último redigido nos seguintes termos:

"**11. DA REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS**

11.1 - O valor constante da proposta da licitante vencedora poderá ser modificado, nos termos da Instrução Normativa nº 18, de 22.12.1997, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, publicada no Diário Oficial da União de 29.12.1997, e da Resolução nº 10, de 08.10.1996, do CCE – Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, publicada no Diário Oficial da União de 14.10.1996. A primeira repactuação só poderá ocorrer desde que observado o interregno de 1 (um) ano a contar da data da sessão pública deste Pregão Eletrônico.

11.1.1 - A repactuação só será admitida a partir do dia em que houver solicitação da empresa contratada, sem efeitos retroativos. O preço repactuado será mantido fixo e irreajustável pelo prazo de 12 (doze) meses, admitindo-se nova repactuação somente após o complemento desse prazo." (sublinhado não consta no original)

23. Dos modelos de edital lançados acima, depreende-se que, enquanto o Basa veda a concessão de efeitos **ex tunc** à repactuação, o MTE admite a retroação desse reajuste, desde que a empresa contratada formalize o pedido dentro de determinado prazo, contado da data da homologação da convenção coletiva.

24. Essa segunda solução me parece mais adequada, especialmente se for considerada a possibilidade de haver assincronismo entre a data-base da categoria e o respectivo dissídio coletivo, circunstância que, no âmbito dos contratos firmados com o Basa, poderia levar as contratadas a solicitar repactuação tão logo se atingisse a data-base das respectivas categorias, independentemente da formalização de dissídio coletivo.

25. Ressalte-se que a solução adotada pelo MTE não representa afronta ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito da União, pois, conforme destacado acima, embora intangível, o direito de ver a repactuação retroagir à data do fato que deu ensejo ao desequilíbrio financeiro, não é indisponível.

26. Destarte, reputo pertinente e oportuno recomendar ao Ministério dos Transportes que

siga o modelo adotado pelo MTE no que tange à repactuação, limitando a retroação de efeitos financeiros aos casos em que a contratada tenha formalizado o pedido dentro de um prazo previamente estipulado no edital de licitação e/ou na minuta de contrato que o acompanha.

27. Quanto às demais irregularidades tratadas nestes autos, compartilho o entendimento do nobre relator, consentâneo com o encaminhamento sugerido pela Sefti.

Com essas considerações, voto por que seja adotada a deliberação que ora submeto a este colegiado.

T.C.U., Sala das Sessões, em 27 de agosto de 2008.

AROLDO CEDRAZ
Revisor